Direito Civil · Responsabilidade Civil

Unidade II
Nexo causal, imputação, temas específicos e funções

Caderno organizado a partir das aulas de 25/09 a 14/11, revisado com base na legislação, na doutrina e na jurisprudência, com as posições do professor Léo Vieira em destaque, tanto as ditas em aula quanto as do seu livro *Responsabilidade civil médico-hospitalar e a questão da culpa no direito brasileiro* (Leonardo Vieira Santos, JusPodivm, 2008).

Opinião de Léo Vieira (aula) · Léo Vieira no livro · Exemplo · Dica de prova · Atenção / divergência

Sumário

1. Pressupostos: conduta e dano
2. Nexo causal: noções gerais
3. Teorias do nexo causal
4. Flexibilização do nexo causal
5. Concausas
6. Teoria do crânio frágil
7. Res ipsa loquitur
8. Excludentes de causalidade
9. Nexo de imputação e erosão dos filtros
10. Responsabilidade civil dos médicos
11. Consentimento esclarecido
12. CDC e a relação médico-paciente
13. Responsabilidade civil dos hospitais
14. Funções da responsabilidade civil
15. Responsabilidade civil na LGPD
16. Responsabilidade civil na internet
17. Parte III · Palestra: as funções da responsabilidade civil (IDP·IBERC)
18. Quadro-resumo e questão de prova
19. Referências

0. Pressupostos: conduta e dano (revisão)

As anotações de 29/10 retomam os pressupostos antes de entrar nos temas da unidade. O nexo causal e o nexo de imputação estão nos itens 1 a 8.

0.1 Conduta

- Deve ser **voluntária**: se não há vontade, não se configura a conduta como pressuposto.
- Pode ser **comissiva ou omissiva**.
- Em regra pensa-se na responsabilidade **direta** (quem dá o murro responde pelo murro), mas a lei prevê hipóteses de responsabilidade **indireta**, em que alguém indeniza dano que não causou (**art. 932 do CC**).

Responsabilidade por fato de outrem (art. 932)

Inciso	Quem responde	Observações
I	Pais, pelos filhos menores	Os filhos devem estar sob sua **autoridade e companhia**; responde quem estava com a criança no momento. Do menor não se analisa culpa.
II	Tutor e curador, pelos pupilos e curatelados	Mesma lógica de autoridade e companhia. O curador do **pródigo** não responde pelos danos que ele causa, pois a incapacidade do pródigo se limita a atos patrimoniais.
III	Empregador ou comitente, pelos empregados e prepostos	Atos no exercício do trabalho ou em razão dele, ainda que fora do estabelecimento ou do horário.
IV	Donos de hotéis, hospedarias e estabelecimentos de ensino que albergam por dinheiro, pelos hóspedes, moradores e educandos	Pressupõe que estejam no **raio de influência** do estabelecimento. Dentro dele, há responsabilidade; fora, analisa-se o caso (ex.: atividade extraclasse organizada pela escola).
V	Quem participou gratuitamente do produto de crime, até a quantia concorrente	Para a doutrina, não é propriamente responsabilidade indireta (senão se responderia por todo o crime), mas aplicação da vedação ao **enriquecimento sem causa**; seria um erro do legislador.

Correção das anotações: a responsabilidade do art. 932 é objetiva

Nas notas consta que as pessoas do art. 932 respondem "de forma subjetiva". O **art. 933 do CC** diz o contrário: elas respondem **"ainda que não haja culpa de sua parte"**, ou seja, objetivamente. O que continua sendo exigido é a **culpa do causador direto** (o empregado, por exemplo), como explica o livro do professor ao tratar do art. 933 (item 12). Exceção: do incapaz não se exige culpa. Quanto à solidariedade, ela não se presume, mas aqui decorre da lei: o **art. 942, p. único**, torna solidárias as pessoas do art. 932. O incapaz responde de forma **subsidiária e equitativa** (**art. 928**), e quem paga tem regresso contra o causador, salvo se for descendente incapaz (**art. 934**).

Responsabilidade por fato de animal e de coisa

- **Animal (art. 936):** o dono ou detentor responde, salvo culpa da vítima ou força maior. A "culpa" mencionada no artigo é a da **vítima** (excludente); o fator de atribuição não é a culpa do dono.
- **Ruína de edifício (art. 937):** há quem a veja como objetiva (o texto não menciona culpa) e quem a veja como subjetiva, pois a "falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta" traduz culpa; caberia ao dono provar que não teve culpa.
- **Coisa caída ou lançada (art. 938):** objetiva; lógica da *actio de effusis et deiectis*. Se uma criança arremessa um objeto pela janela e atinge alguém, responde o habitante. É a raiz da causalidade alternativa (item 3.1).

0.2 Dano

Para a maior parte da doutrina, não há responsabilidade civil sem dano: o núcleo do instituto é o dever de reparar. Para Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, dano é a **lesão a um interesse jurídico tutelado**, patrimonial ou não. Requisitos: violação de interesse jurídico tutelado; **certeza** (não pode ser especulativo); **subsistência** (se já foi reparado, não há mais interesse).

Espécie	Conteúdo
Material	**Danos emergentes**, medidos pela **teoria da diferença** (patrimônio antes e depois da conduta), e **lucros cessantes** (o que a vítima razoavelmente deixou de ganhar).
Moral	Lesão a direito da personalidade. O antigo conceito de "preço da dor" (*pretium doloris*) foi abandonado pela doutrina, mas ainda aparece em tribunais. Pode ser **puro** (sem dano material) e atingir **pessoa jurídica** (Súmula 227 do STJ). Em regra, o mero descumprimento de contrato não gera dano moral; exceção frequente: plano de saúde que nega cobertura.
Estético	Dano imposto à imagem da vítima, não só à aparência física. A **Súmula 387 do STJ** admite cumulá-lo com o dano moral, tratando-o como autônomo.

Léo Vieira no livro: o dano estético não é terceira categoria

Há só dois tipos de dano: **moral ou patrimonial**. Quem sobrevive a um erro médico com deformidade no rosto sofre dano **moral**, que se soma ao sofrimento do procedimento; basta que a indenização seja maior do que a de quem sofreu sem ficar deformado. E o dano estético pode gerar dano **material**: se a vítima for uma **top model**, perderá rendimentos (lucros cessantes). Não há razão para uma terceira categoria.

SANTOS, 2008, *cap.* II, *item* 4.

Ajuste às anotações

As notas dizem que, para Léo, o dano estético "deveria ser considerado dano material". No livro, ele o enquadra como dano **moral e/ou material**, conforme o caso.

Lesões, incapacidade e morte

- A reparação pode ser **in natura** ou **pecuniária**.
- **Lesão com redução ou perda da capacidade de trabalho** (arts. 949 e 950): lucros cessantes durante a convalescença e, depois dela, **pensão**, em regra vitalícia.
- **Homicídio** (art. 948): despesas e alimentos aos dependentes. **Dano em ricochete**: o dano que atinge uma pessoa e, por reflexo, outra.

Quantificação do dano moral

Não há critérios legais objetivos; o juiz arbitra com base em razoabilidade e proporcionalidade. O STJ adota o **método bifásico** (REsp 1.152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2011):

1. **1ª fase:** levantamento de casos semelhantes para achar um valor-base.
2. **2ª fase:** ajuste conforme as circunstâncias do caso (repercussão, grau de culpa, perfil da vítima, capacidade econômica do ofensor etc.).

Valores irrisórios ou exorbitantes abrem exceção à **Súmula 7 do STJ**, permitindo a revisão em recurso especial.

Os "novos danos"

Parte da doutrina defende danos autônomos: **existencial** (projeto de vida); **perda de uma chance** (ex.: jogador prodígio lesionado antes de se profissionalizar); abandono afetivo; dano **espiritual** (ofensa à sensibilidade religiosa); bebê chacoalhado; perda do tempo útil; violação do direito ao esquecimento. **Rodolfo Pamplona e Luiz Carlos Vilas Boas** criticam o fenômeno em "A Torre de Babel das novas adjetivações do dano", por trazer mais efeitos negativos do que positivos.

1. Nexo causal: noções gerais

Também chamado de **nexo de causalidade** ou **liame etiológico**. É a relação de causa e efeito entre a conduta e o dano e um dos pressupostos da responsabilidade civil: para haver dever de indenizar, o dano precisa ter decorrido da conduta analisada. Mesmo quando se dispensa a culpa (responsabilidade objetiva), em regra não se dispensa o nexo; a exceção é o risco integral.

Dos pressupostos, é o que gera **mais debate**, teórico e prático (para Cavalieri, é o pressuposto mais complexo). Para o professor, porém, a ideia de que o nexo é algo *teoricamente* complexo é falsa: a teoria é simples; a complexidade aparece nas situações concretas. Em casos simples (colisão filmada de dois carros) não há dificuldade. Mas surgem nuances: o carro já tinha um dano anterior e bate de novo; após a segunda colisão descobre-se um defeito grave; no direito médico, saber se a sequela veio da doença ou da má prestação do serviço. Não raro, a questão do nexo **deságua na perícia**.

> ***Leitura recomendada pelo professor***
>
> Para estudar nexo causal: **Fernando Noronha**, *Direito das Obrigações*.

> ***Léo Vieira no livro: o nexo é conceito jurídico***
>
> A doutrina majoritária (Cavalieri, Diniz) diz que o nexo causal é uma noção **naturalística**, submetida às leis da natureza. Léo adere à posição minoritária de **Sanseverino** (e Antunes Varela): o nexo é **noção jurídica**. Dois argumentos: (1) pelas leis naturais, uma **omissão** não causa nada; só o tratamento jurídico explica que uma omissão seja "causa" de dano; (2) a simples existência de várias teorias sem consenso já mostra que a escolha da causa é jurídica, e não física.

Também atribui parte da confusão ao fato de o tema ter sido desenvolvido primeiro por **penalistas** e depois transplantado para o direito civil. Na medicina, o problema se agrava porque costuma haver **causalidade múltipla** (doença, reação do organismo, conduta médica).

SANTOS, Leonardo Vieira. Responsabilidade civil médico-hospitalar e a questão da culpa no direito brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2008, cap. II, item 4.

2. Teorias do nexo causal

2.1 Conditio sine qua non (equivalência das condições)

Conceito: todos os antecedentes fáticos imprescindíveis para o resultado são considerados causa. Todos os elos da corrente se equivalem. Não distingue causa, condição ou ocasião. Exposta por **Maximilian von Buri** (penalista alemão, segunda metade do século XIX).

Método de Thyrén (eliminação hipotética): é causa todo antecedente que, retirado mentalmente do encadeamento fático, faria o resultado desaparecer, como o elo que, retirado, quebra a corrente.

Onde é adotada: regra geral do Direito Penal (**art. 13 do CP**), onde tipicidade e culpabilidade contêm a regressão.

Problema: leva a causalidade ao infinito.

Exemplos de aula

- **Erro médico:** poderiam ser processados os professores do médico, o fabricante do bisturi, a mãe do médico. No caso da compressa esquecida, até o fabricante da compressa.
- **Nelson Hungria e o adultério** (quando ainda era crime): pela teoria, o marceneiro que fez a cama seria responsável.
- **Motoboy:** o comerciante que o contratou seria "causa" da destruição da moto no assalto, pois sem a contratação ele não estaria ali.

Léo Vieira no livro: a conditio não serve ao direito civil

Usa o exemplo da **compressa esquecida** (de Camila Azi): pelo método de Thyrén, o fabricante da compressa seria responsável, pois sem compressa não haveria esquecimento. E amplia: os **pais do médico** (que lhe deram a vida) e os **professores que o alfabetizaram** (sem eles, não passaria no vestibular) também seriam causa.

Registra que este é um dos raros pontos de **consenso** entre civilistas e que até no direito penal a teoria está em xeque: o **art. 13, §1º, do CP** (causa superveniente relativamente independente que, por si só, produz o resultado) já a mitiga, como observa Noronha.

Faz ainda um reparo a Noronha: a frase de que as teorias "selecionam, entre as condições, as que são causas" só vale para a adequada e a direta e imediata, pois para a conditio **não há diferença entre causa e condição**.

SANTOS, 2008, *cap.* II, *item* 4.

O que as outras duas teorias têm em comum e de diferente

A causalidade adequada e a direta e imediata **criticam a conditio** e buscam distinguir o mero antecedente fático daquilo que é realmente causa (o marceneiro é mero antecedente; a causa é o adultério). A diferença está no **critério** usado para essa distinção.

O tema é de extrema polêmica: não há posição hegemônica. Segundo o professor, o STJ tem certo predomínio da causalidade adequada, e há muitos julgados (e petições) que se fundamentam nas duas teorias ao mesmo tempo.

2.2 Causalidade adequada

Conceito: só é causa o antecedente que, no normal desenrolar das circunstâncias, seja apto e adequado a produzir aquele dano, segundo a experiência comum (juízo de probabilidade). Origem na doutrina alemã: exposta por **Johannes von Kries** (fisiologista, 1888). Parte do que comumente acontece na vida (*id quod plerumque accidit*). Fazer a cama não é causa adequada do adultério.

Formulações positiva e negativa (Noronha): na **positiva**, causa adequada é a que *favorece* a produção do dano; na **negativa** (atribuída a Enneccerus e prevalente na doutrina), diz-se o que *não* é causa adequada: só se exclui a causalidade quando as consequências forem indiferentes ao fato, estranhas ou extraordinárias. A negativa amplia o âmbito da causalidade.

Prognose retrospectiva: expressão que parece contraditória, mas descreve o método (a expressão vem da doutrina alemã de von Liszt e Rümelin, que desenvolveram a vertente *objetiva* da teoria). Volta-se no tempo (*retrospectiva*), em abstrato, ao momento imediatamente anterior ao dano e, colocando-se nas mesmas circunstâncias do agente, olha-se para frente (*prognose*): era previsível que aquela conduta fosse causa adequada do dano que ocorreu?

Crítica (reconhecida pelo próprio Fernando Noronha, que é adepto): usa muitos conceitos abertos e dá ampla liberdade ao juiz para definir se houve nexo, o que pode gerar insegurança.

Defensores: Fernando Noronha, Sergio Cavalieri Filho, Ruy Rosado de Aguiar (ex-ministro do STJ), Paulo de Tarso Sanseverino, Levenhagen e, segundo o professor, o STJ. Na Alemanha, é a teoria seguida pelo Tribunal Federal (BGH), que inclusive rejeita a probabilidade matemática como critério de causalidade (Otavio Luiz Rodrigues Jr.).

> **Exemplo: o caso do táxi**
>
> O taxista se atrasa, o passageiro perde o voo, embarca no seguinte e o avião cai. O atraso não é causa adequada da queda de uma aeronave; o taxista não responde pela morte.

Léo Vieira pensa assim

Considera a causalidade adequada a melhor teoria, por focar na **previsibilidade** e no **risco que o agente introduziu na sociedade**.

Resposta à crítica da abertura: ela não combina com o Código Civil atual, que é cheio de **cláusulas gerais** justamente para não engessar e envelhecer mais devagar. Aponta ainda uma **incoerência em Pamplona**: critica a abertura da teoria, mas em outras passagens elogia o Código por ser aberto.

Léo Vieira no livro: por que a adequada vence

Conclui que, das três, a causalidade adequada é a que "recebe menos objeções substanciais" e deve prevalecer no direito civil brasileiro, no rastro de Aguiar Júnior, Cavalieri, Levenhagen, Noronha e Sanseverino. Considera a exposição de **Noronha** a melhor sobre o tema.

Previsibilidade: é o fundamento da teoria (Garcez Neto, irmãos Mazeaud), o que aproxima o nexo causal da ideia de culpa. Esse elo entre nexo e culpa será decisivo na sua tese sobre hospitais (item 12).

Contra Gagliano e Pamplona, que veem na teoria um "acentuado grau de discricionariedade do julgador": isso não é defeito num Código "prenhe de cláusulas gerais" (Judith Martins-Costa). A expressão "curso normal das coisas" é um *standard*, como tantos outros que o legislador usa. Rejeitar a teoria por dar liberdade ao juiz seria voltar à técnica casuística do século XIX. E aponta a ironia: o receio de dar poder aos juízes é típico do **panorama oitocentista** que os próprios autores baianos combatem (Ripert).

SANTOS, 2008, *cap.* II, *item* 4.

2.3 Causalidade direta e imediata (e necessária)

Conceito: é causa efetiva o antecedente com vínculo direto e imediato com o dano, além de uma relação de necessariedade entre ambos (subteoria da necessariedade, de Agostinho Alvim). Também chamada de teoria da **interrupção do nexo causal** e, por Noronha, de **causalidade necessária**. Tem raízes em **Pothier**, com o exemplo da "vaca pestilenta": o vendedor, sabendo da doença, vende uma vaca que contamina o rebanho. Ele **responde pela morte dos outros animais** (consequência direta e necessária), mas **não** pelas consequências seguintes: sem os bois, o fazendeiro não ara a terra, perde a colheita e vai à falência. Essas têm "outras causas possíveis" e não decorrem necessariamente da venda.

Atenção: "direto e imediato" não é "próximo no tempo". Para Agostinho Alvim, uma causa **remota** também conta, desde que seja **necessária**, isto é, que não exista outra que explique o dano. E uma causa próxima deixa de contar se um **fato novo e independente** interrompe a cadeia (daí "interrupção do nexo"). A "janela" é mais estreita que a da causalidade adequada. Entre fazer a cama e o adultério não há nexo: não porque a cama foi feita meses antes, mas porque o adultério

decorre de uma decisão livre e independente das pessoas envolvidas, e não, necessariamente, do trabalho do marceneiro.

Crítica (aula): estreita demais; afasta antecedentes que não têm vínculo direto e imediato com o dano, mas que contribuíram para ele, como nos casos de **concausas**.

Críticas de Noronha (adotadas por Léo no livro):

- Na formulação de Alvim, causa seria a condição **necessária e suficiente** do dano ("por não existir outra que explique o mesmo dano"). Exigir as duas coisas é excessivo: dificilmente há uma condição à qual o dano possa ser atribuído com exclusividade.
- Se "direto e imediato" significasse efeito forçoso e inevitável, não se explicaria que o devedor em mora (art. 399), o gestor de negócios (art. 862) e o possuidor de má-fé (art. 1.218) respondam até por danos acidentais.
- Se, para escapar da crítica anterior, toda condição que contribuiu para o dano fosse considerada "necessária", volta-se à equivalência das condições. E, havendo várias causas, escolher "a necessária" depende do ponto de vista de quem julga.

Base legal invocada: art. 403 do CC.

> Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Defensores: Agostinho Alvim, Carlos Roberto Gonçalves, Pablo Stolze, Rodolfo Pamplona Filho e Kühn. Gisela Sampaio da Cruz, pesquisando os tribunais, concluiu que ela prevalece na jurisprudência, embora aplicada de forma atécnica.

No STF: o *leading case* é o **RE 130.764/PR** (rel. Min. Moreira Alves, 1992), sobre a responsabilidade **objetiva** do Estado (mesmo nela se exige o nexo): um foragido, já integrado a uma quadrilha, cometeu assalto muitos meses após a fuga; o voto citou Agostinho Alvim e afastou a responsabilidade do Estado. Em **2020**, no **RE 608.880/MT** (rel. Min. Alexandre de Moraes, **Tema 362** da repercussão geral), o entendimento virou tese: *não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por foragido, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada*. Em ambos, o tempo entre a fuga e o crime e a interposição de fatos novos (como a formação de quadrilha) romperam a cadeia causal.

> ***Argumento topográfico***
>
> O art. 403 está no trecho do Código que trata do **inadimplemento das obrigações** (responsabilidade contratual). Os artigos da responsabilidade extracontratual (arts. 927 e seguintes) não fazem referência à causalidade direta e imediata. Isso enfraquece o uso do art. 403 como prova de que o Código adotou essa teoria para toda a responsabilidade civil. Ainda assim, o STF o aplica por extensão à responsabilidade extracontratual (RE 130.764 e Tema 362).

Léo Vieira no livro: o Código não adotou teoria nenhuma

O argumento topográfico é dele. O art. 1.060 do CC/16 e seu "clone", o art. 403 do CC/02, regulam a **inexecução de obrigações contratuais** e não podem se espraiar para toda a responsabilidade civil. O CC/02 criou um título próprio para a responsabilidade civil (arts. 927 a 954) e não dedicou nenhum artigo às teorias do nexo. Se o legislador quisesse escolher uma, o faria de forma expressa, como a **Argentina** (art. 906, reforma de 1968, que adotou a causalidade adequada), e não "de forma tímida e subliminar" na parte final de um dispositivo deslocado.

Por isso, alinha-se a Azi, Sanseverino e Stoco: o Código **não albergou nenhuma das teorias**. Discorda tanto de quem vê no art. 403 a causalidade adequada (Couto Filho, Garcez Neto, Lisboa) quanto de quem vê a direta e imediata (Orlando Gomes, Gonçalves, Kühn).

SANTOS, 2008, *cap. II, item 4.*

Léo Vieira discorda

Discorda de Stolze e Pamplona. A expressão *direto e imediato* pode gerar **impunidade ou confusões teóricas**, sobretudo quando há **concausas**.

Caso da vaselina (funcionário "A" põe vaselina no frasco de soro; o enfermeiro "B" aplica e o paciente morre): pela necessariedade "A" responde, mas Léo prefere resolver pela causalidade adequada, que pune pela **previsibilidade do risco criado**, sem a rigidez de discutir o que é "efeito necessário".

2.4 As três teorias aplicadas

Caso da Avenida Paralela

X dirige desatento e bate no carro de Y. Por causa da colisão, Y perde o voo para São Paulo, compra outra passagem e o avião cai. X responde pela morte?

Teoria	Responde?	Por quê
Conditio sine qua non	**Sim**	Sem a colisão, Y teria chegado a tempo ao aeroporto.
Causalidade adequada	**Não**	Colisão de trânsito não é causa adequada de morte em queda de avião. Paga os danos do acidente, nunca a morte.
Direta e imediata	**Não**	Não há vínculo direto e imediato com a morte. Pode-se até enxergar alguma necessariedade (sem a colisão, Y não perderia o voo), mas falta o vínculo direto e imediato.

Caso do metanol: onde as teorias podem divergir

Alguém adultera bebida com metanol; ela é revendida várias vezes e vira caipirinha; quem a bebe fica cego ou morre.

- **Direta e imediata:** abre espaço para discutir se há vínculo direto e imediato, dada a distância cronológica e os vários intermediários entre a adulteração e a ingestão.
- **Causalidade adequada:** a condenação de quem adulterou é indiscutível, pois era previsível que isso causasse cegueira ou morte.

Causalidade adequada	Direta e imediata
Fernando Noronha · Sergio Cavalieri Filho · Ruy Rosado de Aguiar · Paulo de Tarso Sanseverino · Levenhagen · STJ (segundo o professor e Sanseverino) · Gabriel Magadan · **Léo Vieira**	Agostinho Alvim · Carlos Roberto Gonçalves · Pablo Stolze · Rodolfo Pamplona Filho · Kühn · art. 403 do CC (para quem o invoca) · STF (RE 130.764 e Tema 362)

2.5 As teorias nos tribunais

- **Divergência generalizada:** Cavalieri, como magistrado, disse que o nexo é o ponto com mais divergências entre julgadores de todos os graus. Sanseverino noticiou que o STJ aplica predominantemente a adequada, mas citou acórdão que, surpreendentemente, usou a equivalência das condições (dados citados no livro de Léo).
- **Decisões intuitivas:** para Tepedino, os tribunais fixam o nexo "de forma intuitiva", de modo eclético e atécnico, e acabam buscando um liame de necessariedade. Há decisões que recorrem apenas ao "bom senso" ou à "razoabilidade", citando uma teoria só para justificar o resultado (Gabriel Magadan, Migalhas, 2024).
- **Coexistência:** Kfouri Neto entende que não há obrigação de adotar uma única teoria; o juiz apreciaria as causas no caso concreto. Noronha adverte que a adequada não é "panaceia": nenhuma solução jurídica pode se basear apenas em relações causais cegas.
- **Gabriel Magadan** (tese de doutorado) adota a causalidade adequada com um parâmetro de **"observador experiente"**: um *standard* de observação baseado na regularidade dos acontecimentos e na previsibilidade objetiva.

Não existe "uma" causalidade adequada

Otavio Luiz Rodrigues Jr. lembra que a teoria tem várias vertentes alemãs: a de **von Kries** (dita subjetiva: o agente responde dentro do que conhecia ou podia conhecer), a de **Rümelin** (objetiva, com a prognose retrospectiva), a de **Traeger** e a **negativa de Enneccerus**. A doutrina brasileira costuma importá-la sem considerar essas diferenças.

3. Flexibilização do nexo causal

O nexo causal vem perdendo rigidez como "filtro" da reparação para não deixar a vítima desamparada, fenômeno estudado por **Anderson Schreiber** como parte da *erosão dos filtros da repara-*

ção (item 8). São exemplos: a causalidade alternativa, a perda de uma chance e o nexo causal probabilístico.

3.1 Causalidade alternativa

Quando o dano certamente foi causado por **um** integrante de um grupo determinado, mas não se sabe qual, todos respondem **solidariamente**, ressalvada a prova individual de que não foi o causador.

Origem: inspirada na responsabilidade pela coisa caída do direito romano (*actio de effusis et deiectis*), hoje refletida no **art. 938 do CC** (coisas caídas ou lançadas de prédio).

> ***Exemplo: os caçadores***
>
> Nove caçadores, com armas iguais, disparam no escuro; um só tiro atinge a vítima, sem que se saiba de quem partiu. Todos respondem.

- **Na doutrina brasileira:** Clóvis do Couto e Silva a expôs em hipóteses restritas (três empreiteiras, sem vínculo entre si, administram uma obra; uma delas causa o dano e não se sabe qual; respondem solidariamente, desde que a relação não seja ocasional e haja homogeneidade de riscos). Pontes de Miranda e Vasco della Giustina (*responsabilidade civil dos grupos*) também a estudaram; Adroaldo Furtado Fabrício lembrava a corrida de carruagens em que uma atropela um passante.
- **Na Europa:** desenvolvida na Áustria por **Franz Bydlinski** (§ 1304 do ABGB), exige risco concreto extremamente elevado de cada evento. Foi acolhida no *Draft Common Frame of Reference* (VI.-4:103) como presunção relativa de causalidade, sem admitir critérios probabilísticos ou imputação parcial.
- **No STJ:** já foi aplicada à queda de objeto de varanda sem identificação do apartamento (condôminos) e à morte de torcedor por ação de torcida rival.

Outros nomes: causalidade *alternativa* ou *anônima* (o autor existe, mas é anônimo dentro do grupo). Pela **teoria clássica**, a vítima teria de provar quem, individualmente, causou o dano ("prove que fui eu"), e o dano ficaria sem reparação. Pela causalidade alternativa, condenam-se **solidariamente** todos os integrantes do grupo, que depois resolvem entre si, na **relação interna** (direito de regresso), quem deve arcar com quanto.

Léo Vieira: teoria "bem interessante", mas exige conexão fática

Considera a teoria **muito interessante** (exemplo típico: a **torcida organizada**). Mas, pelo que se vê na jurisprudência, não se pode condenar "a torcida inteira": é preciso provar a **conexão fática** entre **aquele grupo específico** e o dano. O nexo causal continua sendo o instrumento que ajuda a reconhecer quem pode ser autor (ver Gisela Sampaio da Cruz).

Quem fica de fora:

- **Quem comprovadamente não poderia ter causado o dano.** Ex. de aula: no grupo há um **tetraplégico**, que só poderia agredir mordendo; a perícia não encontra mordida na vítima. Ele é afastado da condenação.
- **Quem não estava lá.** Ser membro da torcida não basta: exige-se **presença física** no grupo que agiu.

Grupo não identificado: se não se sabe sequer quem compunha o grupo, a teoria **não se aplica**, salvo se provas posteriores (filmagens, reconhecimento) permitirem verificar a ligação fática de cada um.

Exemplo de aula: o caso Kevin Espada

Em 20/2/2013, em Oruro (Bolívia), no jogo San José x Corinthians pela Libertadores, um sinalizador disparado do setor da torcida corintiana atingiu e matou **Kevin Beltrán Espada**, torcedor boliviano de 14 anos. Não se sabia quem havia disparado; as autoridades bolivianas prenderam 12 torcedores que estavam no setor (soltos meses depois), e um adolescente assumiu a autoria no Brasil.
Leitura civil (aula): com a filmagem, é possível identificar quem estava ali e condená-los **solidariamente** a indenizar; não se pode condenar quem não estava presente, ainda que fosse membro da torcida. Pela teoria clássica, sem prova de quem disparou, todos ficariam isentos.

Precisão

No caso real, a discussão foi **penal** (prisão na Bolívia). Em direito penal, a responsabilidade é pessoal e não se admite condenar um grupo sem individualizar a conduta. A causalidade alternativa é instituto do **direito civil**: serve para a **indenização**, não para a pena. Use o caso só como ilustração da lógica civil.

3.2 Perda de uma chance

Criada na França (*perte d'une chance*), onde até hoje gera debate, com o objetivo declarado de aumentar as hipóteses de condenação e para permitir a reparação em casos que, pela teoria clássica, deixariam a vítima desamparada por **dificuldade de prova do nexo**.

Regra: quem faz outra pessoa perder uma chance séria e real de obter um ganho ou evitar um prejuízo paga indenização proporcional ao grau da chance perdida, nunca o dano integral.

Show do Milhão (STJ, REsp 788.459/BA, 2005), citado por Cristiano Chaves

Uma participante baiana chegou à pergunta do milhão, mas nenhuma das quatro alternativas estava correta. Não há como saber se ela acertaria; perdeu, porém, uma chance séria (era uma candidata forte). Como havia 1 chance em 4, recebeu 25% dos R$ 500 mil em jogo: **R$ 125 mil**. Pela teoria clássica, não se condenaria o SBT, pois não daria para provar o nexo entre a conduta e a perda do prêmio.

Outros exemplos de aula

- **Direito médico:** um remédio novo salva 70% dos pacientes; o hospital tem o remédio, não o aplica e o paciente morre. Não se sabe se ele estaria entre os 70%, mas médico e hospital podem ser condenados em 70% do dano.
- **Advogado que não recorre:** o cliente foi condenado a pagar R$ 100 mil e cabia recurso. Não há garantia de reversão, mas houve perda de chance; o percentual de êxito (estimado pela jurisprudência) define a condenação.
- **Causa "perdida":** se o recurso não tinha chance real (jurisprudência pacífica em sentido contrário), a teoria **não se aplica**, pois a chance não era séria.

É muito usada no direito médico e em ações contra advogados, porque nessas atividades muitas vezes não é possível garantir o resultado, só a chance. A probabilidade é usada como base para fixar o valor do dano. É tão difundida que há propostas de positivá-la no projeto de reforma do Código Civil.

Léo Vieira: chance ligada ao nexo

A **maior parte da doutrina** (e o STJ) entende a perda de uma chance como um **dano autônomo** (a chance em si).

O professor a trata como **flexibilização do nexo causal**. O argumento: assim como a causalidade alternativa nasceu da coisa caída, a perda de uma chance inspirou o **nexo causal probabilístico**. Esse vínculo reforça que ela está ligada ao nexo, e não a um novo dano.

Léo Vieira no livro: nexo presumido e uso com parcimônia

A teoria, identificada nos tribunais franceses a partir de **1965**, propõe a **mitigação do nexo causal**, "uma espécie de liame etiológico presumido": pune-se a conduta culposa sem prova de que ela foi a causa adequada do dano. Discorda expressamente de quem a trata como espécie de dano (Branco, Gagliano e Pamplona, Garcez Neto). A única particularidade quanto ao dano é a **indenização parcial**, proporcional à chance.

Exemplo do livro: o médico negligente deixa de ministrar remédio com **40%** de chance de evitar a morte, segundo a literatura médica; deve indenizar 40% do que pagaria se o nexo estivesse provado. Se o paciente se cura mesmo sem o remédio, não há dano e nada é devido.

Cautela: no Brasil o nexo é pressuposto indiscutível; a teoria deve ser usada com **parcimônia**, apenas quando houver **grau elevado de culpa**. Critica Alaércio Cardoso, que admitia indenizar mesmo sem prejuízo: "não há como indenizar se não houver dano". Nem na França ela é pacífica: **Savatier** a chamou de "porta aberta a todas as arbitrariedades", e **Chabas** pregou o retorno à teoria clássica.

SANTOS, 2008, *cap.* III, *item* 12.

3.3 Nexo causal probabilístico

Teoria mais recente que a perda de uma chance e a causalidade alternativa, e que vem se expandindo: admite condenar alguém com base na grande probabilidade de que tenha causado o dano. Exemplo: indústria do tabaco (o fumante tem chance muito maior de desenvolver câncer). Ainda tem pouco impacto na jurisprudência brasileira.

Responsabilidade por participação no mercado (*market share liability*): um remédio com defeito de fabricação deixa a vítima sequelada, mas foi produzido por três laboratórios e não se sabe qual deles fabricou a unidade consumida. Cada um é condenado na proporção da sua fatia de mercado.

Crítica de Otavio Luiz Rodrigues Jr. ("Nexo causal probabilístico: elementos para a crítica de um conceito", RDCC, v. 8, 2016)

- **Contradição em termos:** desde Kolmogorov (anos 1920-1930), a causalidade é um caso particular da probabilidade (probabilidade de 100%). Falar em "nexo causal probabilístico" é um abuso de linguagem usado como argumento de autoridade matemática.
- **Falta de método:** se "A" tomou o remédio XYZ por dois anos e morreu, e 10 em cada 1.000 usuários morrem da mesma causa, estatísticas de outras pessoas não provam a causa da morte de "A". Como a probabilidade de qualquer evento causar algo é sempre maior que zero, pais, restaurante, alfaiate do doente também seriam "causa provável".
- **Nome correto:** o que se propõe é, na verdade, **responsabilidade por presunção**, que precisa de fundamento jurídico próprio (e, de preferência, do legislador), e não de princípios genéricos como dignidade ou solidariedade.
- **Risco:** transformar a responsabilidade civil em instrumento de **justiça distributiva** ou de "securitização forçada" de agentes econômicos. Na Alemanha, a causalidade adequada continua central e não se fala em flexibilização generalizada do nexo.
- Na perda de uma chance, o uso do adjetivo "probabilístico" é aceitável em sentido figurado ("licença poética").

4. Concausas

No mundo dos fatos, quase todo dano tem mais de uma causa. **Concausa** ("con" = junto) é uma segunda causa que se soma à conduta do agente e, **junto com ela**, produz ou agrava o dano. Ela reforça, acelera ou agrava o resultado, mas **não apaga** a conduta do agente.

Palavra-chave (Pamplona e Stolze)

Concausa é o acontecimento que, anterior, concomitante ou superveniente ao antecedente que deflagrou a cadeia causal, **acrescenta-se** a ele em direção ao evento danoso.

4.1 A grande divisão: a outra causa agiu junto ou sozinha?

	Concausa	Causa independente
O que é	Causa que **só fez estrago porque a conduta do agente já existia**. As duas agem **juntas**.	Causa que produz o dano **sozinha**; aconteceria do mesmo jeito sem a conduta do agente.
Efeito no nexo	**Não rompe** o nexo causal.	**Rompe** o nexo causal.
O que o agente indeniza	O dano **final**, inteiro (podendo dividir a conta com outros responsáveis).	Só o que ele mesmo causou **antes** da causa independente; não o dano final.
Exemplo	Pedro, esfaqueado por João, morre porque a ambulância ficou presa num engarrafamento. O engarrafamento só matou porque Pedro estava ferido.	A ambulância é esmagada por um caminhão e morrem todos, inclusive o motorista, que estava saudável. O caminhão mataria Pedro mesmo sem a facada.

Teste rápido

Pergunte: **essa outra causa, sozinha, sem a conduta do agente, teria produzido o dano?** Se **não**, é concausa e o agente responde pelo dano final. Se **sim**, é causa independente e rompe o nexo.

Sobre os nomes

A doutrina civil (Stolze e Pamplona, Cavalieri) também chama a concausa de **causa relativamente independente** e a outra de **causa absolutamente independente**. São nomes herdados do direito penal, onde a teoria nasceu, mas aqui o que interessa é o efeito **civil**: quem indeniza e quanto. "Relativamente" porque a concausa não veio da conduta do agente (é independente na origem), mas só produziu o dano por causa dela (é dependente no efeito).

4.2 A metáfora do rio (Pamplona e Stolze)

- **Conduta do agente:** o rio principal, correndo em direção ao dano (o mar).
- **Concausa:** um rio secundário que, em vez de desaguar no mar, **deságua no rio principal** e o torna maior. O rio continua o mesmo, só que mais forte.
- **Causa independente: outro rio**, que chega ao mar sozinho. Produz o dano por si só e **quebra o nexo** com a conduta anterior.

4.3 Tipos de concausa (pelo momento em que aparecem)

Tipo	Exemplo	Consequência civil
Preexistente (já existia antes)	Pedro é hemofílico; João lhe faz um corte leve e Pedro sangra até morrer.	João indeniza a **morte** (art. 948). Ligação com a teoria do crânio frágil (item 5) e a crítica sobre a previsibilidade da fragilidade.
Concomitante (ao mesmo tempo)	João aponta a arma e atira; no mesmo instante, Pedro tem um infarto pelo susto.	João indeniza o dano decorrente do infarto.
Superveniente (depois)	Pedro, ferido, morre porque o socorro atrasou (estrada interditada, engarrafamento).	João indeniza a **morte**: sua conduta colocou Pedro na situação de emergência.

Cuidado com o fato posterior que age sozinho: se Pedro chega bem ao hospital e morre num **incêndio** no prédio, o incêndio mataria qualquer pessoa ali. Não é concausa: é causa que produziu o resultado por si só e rompe o nexo. João indeniza só os danos da **lesão** (despesas de tratamento, lucros cessantes, dano moral e estético, arts. 949 e 950), não a morte.

4.4 Como decidir: a causalidade adequada

Na linha do Léo, a pergunta para cada caso é a da causalidade adequada: **era normal e previsível que a conduta do agente terminasse naquele dano?**

- Facada e morte por demora no socorro: **previsível**. Ferimento grave mais atraso no atendimento pode matar. A facada é causa adequada da morte.
- Facada e morte por caminhão que esmaga a ambulância, ou por incêndio no hospital: **extraordinário**. A facada não é causa adequada dessa morte.

É justamente nas concausas que Léo vê a fraqueza da teoria direta e imediata: exigir uma causa "necessária" e exclusiva complica os casos em que duas causas se somam (item 2.3).

4.5 Quem paga: solidariedade ou redução

A concausa é...	Regra
Conduta de outra pessoa	Os autores respondem **solidariamente** (art. 942 do CC): a vítima pode cobrar tudo de qualquer um, e quem paga cobra a parte do outro. Ex.: um segura a vítima e o outro bate.
Conduta da própria vítima	Não há solidariedade; a indenização é **reduzida** conforme a gravidade da culpa da vítima (art. 945, culpa concorrente).
Condição da vítima ou fato natural (hemofilia, engarrafamento)	O agente responde pelo dano final; não há com quem dividir.

4.6 Casos de aula

Caso	Natureza	Consequência civil
Pessoa com crise de pressão (que não a mataria) está na ambulância; um caminhão esmaga a ambulância e ela morre.	Causa independente	Só o motorista do caminhão responde pela morte.
Pessoa leva um murro e sofre hemorragia; na ambulância, um caminhão provoca capotamento; a hemorragia somada ao capotamento a mata.	Concausa	Quem deu o murro e quem causou o acidente respondem **solidariamente** pela morte.
Agressão grave + tsunami que mata todos no local.	Causa independente	O agressor indeniza só os danos das lesões causadas antes do tsunami.
Agressão + atendimento hospitalar a tempo; a vítima sobrevive.	Intervenção eficaz interrompe o curso lesivo	O agressor indeniza os danos físicos e estéticos da lesão.
Agressão + estradas interditadas e demora no socorro; a vítima morre.	Concausa superveniente	O agressor indeniza a morte.

5. Teoria do crânio frágil

De origem anglo-saxã (*thin skull* ou *eggshell skull rule*): o agente responde pelo resultado mais grave, ainda que decorra de vulnerabilidade prévia da vítima. O causador "toma a vítima no estado em que a encontra"; a fragilidade funciona como concausa preexistente. Observação de aula: algumas pessoas, mesmo adultas, conservam o crânio frágil.

Crítica adotada em aula (Anderson Schreiber)

Schreiber defende que a teoria não deve ser aceita, por incompatibilidade com a teoria geral da responsabilidade civil: para responder pelo resultado mais grave, é preciso **conhecimento prévio da fragilidade** (ou elementos que permitam prevê-la). Quem dá um cascudo sem querer matar não responde pela morte de quem tinha crânio frágil, salvo se sabia da condição.

Exemplo de aula: na frente do "Hospital do Crânio Frágil" sai um homem de avental do hospital; um sujeito forte o empurra rudemente e ele "se desmonta". Havia sinais para prever a fragilidade; aí responde pelo resultado mais grave.

> ***Para a prova discursiva***
>
> Aponte a tensão: na concausa preexistente clássica (hemofílico), o agente responde pelo resultado final; a crítica restringe essa solução com base no conhecimento ou na previsibilidade da fragilidade, o que dialoga com a causalidade adequada.

6. Res ipsa loquitur

"A coisa fala por si." Teoria usada nos EUA: quando a situação é **evidente, grosseira ou impactante**, presume-se a culpa do médico e inverte-se o ônus de prová-la. Exemplo: o paciente descobre uma compressa no abdômen após a cirurgia. É pouco usada no Brasil.

No Brasil, tem impacto menor, porque o mesmo efeito prático pode ser obtido pela **inversão do ônus da prova** do CDC (art. 6º, VIII) ou do CPC (art. 373, §1º).

Léo Vieira no livro: res ipsa loquitur

No segmento médico, a teoria funciona como **presunção de culpa** do profissional. Requisitos (Joseph King Jr., via Kfouri Neto): (a) o dano resulta de fato que normalmente não ocorre sem negligência; (b) foi causado diretamente pelo médico ou por quem atua sob seu controle; (c) as circunstâncias indicam que o paciente não o produziu.

Exemplos: objeto esquecido no corpo após cirurgia eletiva; médico que retira o **pulmão saudável** e deixa o doente.

A presunção é **juris tantum** (admite prova em contrário), com base na doutrina norte-americana (Speiser). Por isso discorda de quem admite dispensar a perícia com base nela. No Brasil, aproxima-se da inversão do ônus pela **verossimilhança** (art. 6º, VIII, CDC): se a coisa "fala por si", a alegação é verossímil. Conclui que a teoria "não representa grandes inovações" no direito brasileiro, ao contrário da perda de uma chance.

SANTOS, 2008, *cap.* III, *item* 11.

7. Excludentes de causalidade

Excludente de **ilicitude**, de **causalidade** e de **responsabilidade** são como três círculos com zonas de interseção, mas não se confundem:

- **Ilicitude** (legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, art. 188 do CC): o ato deixa de ser ilícito, mas nem sempre afasta o dever de indenizar. Existe responsabilidade civil por ato lícito (arts. 929 e 930).
- **Causalidade:** impede a configuração do nexo. Quase sempre é também excludente de responsabilidade, mas nem sempre: no **risco integral** indeniza-se mesmo sem nexo (dano ambiental, STJ REsp 1.374.284/MG; dano nuclear, art. 21, XXIII, "d", da CF; o exemplo de aula do raio e do INSS).

Léo Vieira no livro: cada excludente em seu círculo

Figura	Ilicitude	Responsabilidade	Causalidade	Por quê
Estado de necessidade (art. 188, II)	Exclui	**Não exclui** (art. 929)	Exclui	Ex.: dois náufragos e uma tábua que só suporta um; quem arromba a porta do vizinho para salvar criança na sacada. Não há ilícito, mas indeniza quem não foi culpado pelo perigo.
Legítima defesa	Exclui	Exclui	Exclui	É reação instintiva e inevitável. A putativa não exclui o dever civil; se atinge terceiro, indeniza e tem regresso (art. 930, p. único).
Estrito cumprimento do dever legal	Exclui	Exclui	Exclui	Ex.: policial que fere fugitivo, salvo excesso. Não se podia exigir outra conduta.
Exercício regular de direito	Exclui	Exclui	**Não exclui**	Ex.: protesto de título do devedor em mora. O protesto é causa adequada da "negativação", mas era uma opção do credor. Limite: abuso de direito (art. 187).
Caso fortuito / força maior	—	Exclui	Exclui	Inevitabilidade.
Cláusula de não indenizar	—	Exclui	—	Só na responsabilidade contratual; vedada no CDC; admissível só entre partes em igualdade (Gagliano e Pamplona).

Discorda de Gagliano e Pamplona, que incluem o estado de necessidade entre as excludentes de responsabilidade, e da definição deles de excludente como o que "rompe o nexo", pois o exercício regular de direito exclui a responsabilidade sem romper o nexo.

SANTOS, 2008, *cap. II, item 5.*

7.1 Fato exclusivo da vítima

O próprio prejudicado dá causa, sozinho, ao dano. Como é excludente de **causalidade** (e não tema do nexo de imputação), pode ser alegada mesmo na responsabilidade objetiva.

Léo Vieira prefere "fato"

Usa **"fato exclusivo da vítima"**, que considera a melhor doutrina, em vez de "culpa exclusiva". O agente pode ser **inimputável** e ainda assim o fato ser exclusivo da vítima: se um **menor de idade** pula na frente do carro, o motorista pode alegar fato exclusivo da vítima. Como o menor é inimputável, não faz sentido avaliar sua culpa. O mesmo raciocínio vale para "fato de terceiro".

Exemplos

- **Cirurgia estética:** o médico faz recomendações pós-operatórias; a paciente faz o contrário e o nariz fica com problema.
- **Linha férrea cercada:** o pedestre corta a cerca e anda nos trilhos em local proibido; o STJ afasta a responsabilidade da concessionária.

Não confundir com culpa concorrente (art. 945), que não exclui nada: só reduz o valor da condenação.

Exemplos do livro de Léo

- **Clássico:** o motorista, em velocidade regulamentar, não consegue evitar a morte de quem se joga sob as rodas do veículo.
- **Cirurgia plástica:** o médico proíbe tomar sol na cicatriz no pós-operatório; a paciente desobedece e o resultado fica comprometido. Não há indenização pelos danos da exposição solar.

7.2 Fato exclusivo de terceiro

"Irmão" do fato da vítima: um terceiro determina o dano, e não a pessoa que seria tida como responsável. Exemplo: alguém empurra um pedestre contra um carro que passava. Exemplo do engavetamento: o caminhão bate na sua traseira e empurra seu carro contra o da frente.

Léo Vieira no livro: "fato", e não "culpa", de terceiro

A lei fala em "culpa de terceiro", mas, com Sanseverino, Léo prefere "fato" ou "intervenção" de terceiro (termo da Diretiva 85/374/CEE), porque o fato de terceiro **não precisa ser culposo** para romper o nexo. Exemplos: criança arremessada por um terceiro (ainda que inimputável) sob as rodas de um carro; paciente coagida por terceiro a levantar os braços logo após uma **mamoplastia**, comprometendo a posição dos seios.

SANTOS, 2008, *cap. II, item 5, e cap. III, item 10.*

Para a prova

No transporte de pessoas, o fato de terceiro **não** exclui a responsabilidade do transportador (art. 735 do CC; **Súmula 187 do STF**), que tem ação regressiva.

7.3 Caso fortuito e força maior

Nas anotações aparecem os **arts. 392 e 393**. O art. 392 trata da responsabilidade nos contratos benéficos e onerosos (dolo ou culpa); a regra do fortuito está no art. 393.

> Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
> Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

A própria lei destaca a inevitabilidade do evento (posição também do STJ). Exemplo: um furacão arrasta um carro para cima de outro na calçada.

Alguns autores distinguem: **força maior** ligada a eventos da natureza; **caso fortuito** ligado a fatos humanos (cabo que se rompe, freio que falha). Mas o critério não é bem definido e os autores divergem, chegando a inverter os conceitos.

Léo Vieira: são a mesma coisa

Não existe razão jurídica para distinguir caso fortuito de força maior. O que importa é a **inevitabilidade** do evento, que é o que a lei exige.

Léo Vieira no livro: o "terreno pantanoso" do fortuito

A equiparação tem raízes antigas: Jaime Aires (1941) e o português M. Rocha (século XIX) já chamavam ambos de "acaso". Desde o CC/16 (art. 1.058) e hoje no art. 393, o traço característico é a **inevitabilidade**; o STJ já afirmou (1998) que o traço não é a imprevisibilidade, mas a inevitabilidade.

Três correntes doutrinárias, nenhuma com respaldo legal:

- **Romana (Ulpiano):** caso fortuito é o imprevisível (e por isso inevitável); força maior é o inevitável, ainda que previsível (Gagliano e Pamplona, Couto Filho, Lisboa).

- **Natureza x fato humano:** força maior seriam raios, inundações e terremotos; caso fortuito, fatos humanos ou de causa desconhecida (Diniz, Gonçalves, Baptista).
- **Josserand e Agostinho Alvim:** fortuito **interno** (ligado à pessoa, à coisa ou à empresa do agente) x **externo** (equivalente à força maior, o *Act of God*). Só o externo excluiria a responsabilidade.

Sobre o fortuito interno, afirma que é "pura doutrina": não há norma que diga que ele não exclui a responsabilidade, nem mesmo no CDC, cujos arts. 12, §3º, e 14, §3º, sequer mencionam o fortuito. Quanto ao advérbio "só" desses artigos, acompanha Denari e Sanseverino: o fortuito **continua excluindo** a responsabilidade no CDC, que não adotou o risco integral (contra Rizzatto Nunes).

SANTOS, 2008, *cap.* II, *item* 5.

Fortuito interno x externo

Doutrina que vem ganhando espaço na seara consumerista, sem previsão legal expressa. Para parte dela, força maior seria gênero e caso fortuito espécie, que se divide em:

- **Interno:** dano inevitável **ligado à atividade-fim**. Não quebra o nexo; não afasta o dever de indenizar. Ex.: **Súmula 479 do STJ** (fraudes de terceiros em operações bancárias).
- **Externo:** dano inevitável **não ligado à atividade-fim**. Quebra o nexo.

Fortuito durante a mora

> Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada.

8. Nexo de imputação (fatores de atribuição)

Parte da doutrina fala em três pressupostos da responsabilidade civil; outra parte, em quatro, incluindo o nexo de imputação. Ele reúne os fundamentos que justificam que X pague o prejuízo sofrido por Y. Se X foi condenado, necessariamente: agiu com culpa, criou um risco, enquadrou-se na responsabilidade por equidade ou numa lei que prevê responsabilidade objetiva. **Sem fundamento, não há condenação**: se X demonstrar que nenhum deles se aplica, a ação deve ser julgada improcedente.

No modelo contemporâneo (pluralismo de imputação, chamado em aula de fatores "total flex"), há quatro fatores:

Fator	Natureza	Fundamento	Base legal
Culpa	Subjetiva	Reprovação da conduta: dolo ou culpa em sentido estrito (negligência, imprudência, imperícia).	**arts. 186 e 927, caput**
Risco criado	Objetiva	Quem cria um risco paga os prejuízos dele decorrentes, independentemente de culpa.	**art. 927, p. único**
Equidade	Objetiva	Razoabilidade: não seria razoável a vítima ficar sem indenização (ex.: incapaz, estado de necessidade).	**arts. 928, 929 e 930**
Disposição legal	Objetiva	A lei impõe o dever de indenizar independentemente de culpa.	Decreto 2.681/1912 (ferrovias)

Léo Vieira no livro: quatro pressupostos

Adota quatro pressupostos: **conduta humana, dano, nexo causal e nexo de imputação** (com Aguiar Júnior, que fala em "fator de atribuição"). O nexo de imputação ocupa o lugar que um dia foi do ato ilícito como único fundamento da responsabilidade.

Faz um reparo a Noronha, para quem sem culpa ou risco não há obrigação de indenizar: o risco é o **principal** fundamento da responsabilidade objetiva, mas não o único. A **equidade** também é fator de atribuição (art. 928, responsabilidade do incapaz).

Não confundir nexo de imputação com **imputabilidade** (capacidade de entender e querer, pressuposto da culpa). O incapaz é inimputável e, ainda assim, pode ter contra si nexo de imputação fundado na equidade (art. 928).

SANTOS, 2008, *cap.* II, *item* 4.

Culpa presumida

Para o réu, é melhor que o caso seja de responsabilidade subjetiva: o ônus de provar a culpa é do autor. Na **culpa presumida** há inversão desse ônus. Se não se diz mais nada, a presunção é **juris tantum** (admite prova em contrário). Uma presunção **juris et de jure** (absoluta) equivaleria, na prática, à responsabilidade objetiva.

8.1 A culpa segundo o livro de Léo

Léo Vieira no livro: conceito e aferição da culpa

Conceito: culpa é o **erro de conduta** de quem não se comporta da maneira normalmente esperada para evitar danos a terceiros, independentemente de o dano ocorrer (linha dos irmãos Mazeaud e de Henri de Page). Rejeita o conceito de Savatier (inexecução de um dever que o agente podia conhecer e observar), por ser genérico e levar à confusão entre cul-

pa e lesão a direito: alguém pode dirigir sem habilitação, em alta velocidade, e não causar dano algum. Há culpa sem dano.

Aferição em abstrato, temperada: compara-se a conduta com um *standard* (o "bom pai de família", o homem médio), mas o padrão varia conforme o caso concreto. O padrão para um sertanejo acusado de ofensa verbal não é o mesmo de um morador de metrópole com curso superior; para o médico, é o "médico prudente". Evita a expressão "culpa objetiva" para a culpa em abstrato, para não confundir com responsabilidade objetiva. A aferição em concreto só vale onde a lei manda (comodatário e depositário, arts. 582 e 629).

Espécies: dolo (inclusive eventual); imprudência (conduta açodada, em regra comissiva); negligência (desídia, em regra omissiva); imperícia (atuar sem aptidão técnica). Considera desnecessária a divisão entre culpa "ordinária" e "profissional" (Kfouri Neto).

Culpa presumida não é responsabilidade objetiva: é erro frequente tratar uma como a outra. Na presunção *juris tantum* só se inverte o ônus; a presunção *juris et de jure* é que equivale à responsabilidade objetiva (já advertia Josserand).

Seguro: discorda de Orlando Gomes, que previa a "destruição" da responsabilidade civil pela expansão do seguro. O seguro não pode ser generalizado, acaba com o efeito intimidatório da indenização e sempre tem limites de valor (ex.: o seguro obrigatório de veículos raramente cobre todo o dano).

SANTOS, 2008, *cap. II, item 6.*

> ***Fora do conteúdo cobrado***
>
> Léo **não deu** a **regra de Hand** (fórmula de Learned Hand, *United States v. Carroll Towing*, 1947: há culpa quando o custo da precaução, B, é menor que a probabilidade do dano vezes sua gravidade, P × L) nem o **texto de Oitaven**. Fica só como referência.

8.2 Subteorias do risco

Dentro do fator "risco", a doutrina (por exemplo, Cavalieri Filho) identifica variações sobre **qual risco** justifica o dever de indenizar sem culpa:

Subteoria	Quem responde
Risco-proveito	Quem tira proveito (lucro) da atividade arca com seus riscos (*ubi emolumentum, ibi onus*).
Risco profissional	O dever de indenizar decorre da atividade ou profissão da vítima (origem nos acidentes de trabalho).
Risco excepcional	Atividades de risco fora do comum (energia elétrica de alta tensão, material radioativo).
Risco criado	Quem cria um risco com sua atividade responde, haja ou não proveito. É a adotada pelo **art. 927, p. único**.
Risco integral	Modalidade extremada: indeniza-se mesmo sem nexo, sem admitir excludentes (dano ambiental, nuclear).

O professor anunciou que esse debate seria aprofundado em aula.

Léo Vieira no livro: as cinco modalidades do risco

Segue a classificação de **Cavalieri Filho**, mas em ordem histórica:

1. **Risco profissional:** nasceu com Saleilles (1897), para os acidentes de trabalho.
2. **Risco-proveito:** derivado de Josserand. Problema: definir e provar o "proveito" troca a difícil prova da culpa pela difícil prova do proveito.
3. **Risco criado:** também de Josserand ("quem cria um risco deve suportar as consequências"). Mais simples e foi a que **prevaleceu**, na doutrina e no **art. 927, p. único**.
4. **Risco excepcional:** de Ripert; atividades anormalmente perigosas (alta tensão, energia nuclear). Teve pouca repercussão.
5. **Risco integral:** modalidade extremada que dispensa até o nexo (Noronha a chama de "responsabilidade objetiva agravada"). Raríssima no Brasil: acidente de trabalho (Lei 8.213/91) e seguro obrigatório de veículos (Leis 6.194/74 e 8.441/92), segundo Sanseverino.

Risco x perigo (com J. J. Calmon de Passos e Hofmeister): *perigo* é a probabilidade de dano por algo externo, fora do poder de opção do agente; *risco* é o dano que decorre de uma **decisão**. Só o risco integral indeniza danos do perigo. Essa distinção é a base do argumento de que a **medicina lida com perigo, não com risco** (item 9).

Fundamento do CDC: discorda de Cláudia Lima Marques (responsabilidade "objetiva não culposa" fundada no defeito como ato antijurídico): no Brasil o ato ilícito pressupõe culpa. Para Léo, o CDC partiu do **risco criado**, mas acabou criando fundamento novo: o fornecimento de produto ou serviço **defeituoso** (violação do dever de incolumidade).

SANTOS, 2008, *cap.* II, *item* 7.

8.3 Erosão dos filtros da reparação

Expressão de **Anderson Schreiber** (*Novos paradigmas da responsabilidade civil*): os pressupostos tradicionais (culpa, nexo e dano), que funcionavam como "filtros", foram sendo flexibilizados para facilitar a reparação.

- **Culpa:** perde espaço para presunções de culpa e para a responsabilidade objetiva.
- **Obrigações de meio e de resultado (René Demogue):** nas de resultado, não alcançar o resultado faz presumir o inadimplemento.
- **Inversão do ônus da prova:** **art. 6º, VIII, do CDC** e carga dinâmica do **art. 373, §1º, do CPC**.
- **Nexo:** causalidade alternativa, perda de uma chance, nexo probabilístico. A ideia por trás (anotação de aula): que o maior número possível de vítimas obtenha algum tipo de ressarcimento.
- **Risco:** expande sua incidência na sociedade pós-industrial.

Ope legis x ope judicis

Corrente	O que significa	Exemplos
Ope legis ("por força da lei")	A própria lei já presume a culpa ou distribui o ônus da prova; o juiz não precisa decidir nada, apenas aplicar.	**arts. 12, §3º, e 14, §3º, do CDC** (o fornecedor é que prova a excludente); **art. 38 do CDC** (publicidade).
Ope judicis ("por obra do juiz")	A inversão depende de decisão do juiz no caso concreto, presentes os requisitos legais.	**art. 6º, VIII, do CDC** (verossimilhança ou hipossuficiência); **art. 373, §1º, do CPC** (carga dinâmica).

Anotação de aula: na prática, a discussão sobre a **culpa** acaba acontecendo **dentro do tópico do nexo causal**, porque, flexibilizado o nexo e invertido o ônus, o debate passa a ser se o réu consegue provar que não deu causa ao dano.

> **Anotação incompleta**
>
> As notas registram só os nomes das correntes. O quadro acima traz o sentido técnico usual das expressões (direito processual e do consumidor). Confira com o professor em que contexto ele as usou.

A teoria geral terminou; daqui em diante, temas específicos

Parte II · Temas específicos

9. Responsabilidade civil dos médicos

9.1 Contexto

Com o CDC (1990), temeu-se importar o cenário dos EUA, onde médicos respondem de forma muito severa (o tema chegou a campanhas presidenciais). O professor é contra essa radicalização. O direito médico é sensível porque trata do bem mais importante (a vida) e envolve muito dinheiro; além disso, para a responsabilidade civil ser efetiva, é preciso que o réu tenha patrimônio para pagar.

Por que evitar condenações exageradas: pela análise econômica do direito (AED), condenações desarrazoadas geram reação: encarecimento (seguros caros, como nos EUA), indisponibilidade de serviços e **medicina defensiva** (item 9.7). São causas com transcendência pela nobreza do bem em jogo.

Léo Vieira no livro: nem "responsabilidade eufemística", nem "caça às bruxas"

A ideia que atravessa todo o livro é a de um **meio-termo**: nem a impunidade dos médicos, nem a sua punição exagerada. Os movimentos da história são pendulares (como as indenizações milionárias por dano moral logo após 1988, seguidas de valores ínfimos).

Histórico: o Código de Hamurabi previa amputar as mãos do médico que não evitasse a morte; a Lex Aquilia previa morte ou deportação. No século XIX, com o prestígio científico, veio a "**responsabilidade eufemística**": o médico se via "acima do bem e do mal". No **caso Hélie** (França, 1825), o médico amputou sem necessidade os dois braços de um bebê no parto e obteve da Academia de Medicina laudo de irresponsabilidade. A virada veio com o **parecer do Procurador-Geral Dupin (1836)**: o médico responde, desde que haja culpa, e os tribunais devem ser prudentes. No Brasil, a "imunidade jurídica" durou até cerca de 1950, apesar do art. 1.545 do CC/16; as ações cresceram sete vezes nos anos 1990.

Riscos da "estadunização": nos EUA, indenizações médias saltaram de US$ 12 mil (1970) para mais de US$ 100 mil (1986); cirurgiões pagavam até US$ 100 mil por ano de seguro; o presidente Bush propôs teto de US$ 250 mil para danos não econômicos. Ainda assim, lá a responsabilidade médica é **subjetiva**. Objetivá-la no Brasil seria um catalisador da crise "inexistente até nos EUA".

Contra a tarifação: critica projetos que limitam indenizações por erro médico (ex.: PL 6.659/2002, teto de 100 salários mínimos), pois tratam igualmente situações desiguais.

Saída proposta: se a sociedade decidir que o paciente não deve suportar sozinho a álea da medicina, a solução é a **socialização do perigo** por um **fundo securitário** obrigatório, como no acidente de trabalho (art. 7º, XXVIII, CF), e não a objetivação.

SANTOS, 2008, *cap.* III, *itens* 3, 4 e 6.

Léo Vieira no livro: as especificidades da medicina

Ciência inexata: "não há doenças, há doentes" (Kfouri Neto): dois pacientes com o mesmo mal e o mesmo tratamento podem ter cura e morte. Exemplos de danos sem culpa: **alergia ao talco das luvas** do cirurgião; **choque anafilático** imprevisível (casos de Clara Nunes e Cláudia Liz); acórdão do TAPR absolveu médicos porque a ciência não dispõe de exame que detecte com eficiência a intolerância a uma droga. Mas responderiam se não adotassem as medidas de urgência previstas nos manuais.

Perigo, não risco: doenças e morte existem com ou sem médicos. Se a humanidade abdicasse da energia nuclear, eliminaria o risco radioativo; se acabasse com a medicina, as mortes aumentariam. Excepcionalmente o médico entra no campo do risco, por exemplo ao escolher técnica inovadora e pouco conhecida no lugar de outra igualmente eficaz e dominada.

SANTOS, 2008, *cap.* III, *item* 5.

9.2 Natureza

- **Contratual, em regra.** Excepcionalmente extracontratual: o médico socorre alguém inconsciente na rua; como o contrato exige encontro de vontades, aplica-se o regime extracontratual, com todos os seus impactos.
- **Outras exceções extracontratuais (livro de Léo):** atendimento a menor impúbere não representado; negativa de atendimento; dano a terceiros, como **atestado médico indevido** que prejudica uma empresa. Léo discorda de Baú e Aguiar Júnior, que viam relação extracontratual no atendimento por plano de saúde: o paciente pode desistir ao chegar ao consultório, e o fato de o médico credenciado não poder recusar não afasta o contrato (contratos "necessários"). A natureza do contrato é de **contrato atípico** com elementos da prestação de serviços (Kühn): o paciente é coparticipante do êxito do tratamento.
- **Sempre subjetiva no Brasil:** o médico só é condenado se agiu com culpa. Mesmo aplicando o CDC, o **art. 14, §4º** exige culpa dos profissionais liberais; além disso, o **art. 951 do CC** é norma específica para profissionais de saúde.
- Só é responsabilidade médica a que ocorre **no exercício da profissão**. Se o médico bate o carro a caminho do hospital, responde como qualquer pessoa. Se bate no carro de alguém e não presta socorro, é conduta **omissiva** comum, não responsabilidade profissional. A responsabilidade médica pode decorrer de condutas comissivas ou omissivas no exercício da profissão.

9.3 Obrigação de meio, lex artis e aferição da culpa

Em regra, obrigação de **meio**: a medicina não é exata; o procedimento que salva 99 pessoas pode matar 1. O médico deve seguir o **consenso médico**, a lex artis ad hoc: para tal quadro clínico, indica-se tal procedimento (ainda que com 1% de risco). Faz o melhor possível, sem garantir o resul-

tado. A lex artis inclui protocolos validados (como o ATLS, *Advanced Trauma Life Support*) e consensos das sociedades médicas. **Regra:** é inadmissível condenar o médico que seguiu a lex artis, ainda que o resultado tenha sido desfavorável.

Aferição da culpa: em abstrato, comparando a conduta com a do **médico médio da mesma especialidade**. Quem esclarece isso, inclusive o nexo, é o **perito**.

Léo Vieira no livro: as fases do ato médico e a culpa

- **Anamnese:** coleta de dados; o médico tem obrigação de **resultado** quanto ao **sigilo** do que ouviu.
- **Diagnóstico:** fase em que a álea torna comuns os erros escusáveis; só há falha em caso de **erro evidente**.
- **Tratamento:** o mesmo tratamento cura uns e mata outros.

Exemplos de culpa: imprudência, operar sem diagnóstico correto e sem preparo do paciente; negligência, abandonar o paciente; imperícia, o obstetra que corta a **bexiga** da parturiente na cesárea.

Lex artis ad hoc (Martínez-Calcerrada, via Kfouri Neto): critério para avaliar o ato concreto, considerando as características do profissional, os recursos materiais, a especialidade, a complexidade do ato e o estado do paciente. O especialista é avaliado com mais rigor que o generalista; o médico que opera vários pacientes numa noite de desastre não é tratado como o de uma cirurgia marcada. A culpa médica é a culpa comum, apurada em abstrato com esse padrão (discorda de Diniz, que via "espécie particular de culpa").

Nexo: aplica a causalidade adequada (Iturraspe: o juiz como "observador retrospectivo", com a previsibilidade de um profissional da medicina). Ex.: não responde o médico pela morte da parturiente por ruptura de um edema congênito sem relação com o parto (Gonçalves).

Terminologia: usa "**erro médico**" só para a atuação culposa (pode haver erro médico sem dano) e "**fato escusável**" para o desfecho danoso sem culpa, causado pela álea da medicina.

Dano: discorda de Kfouri Neto, que separa danos "físicos": o dano é sempre patrimonial ou moral. O art. 951 do CC remete aos arts. 948 a 950 para a liquidação.

SANTOS, 2008, *cap.* III, *itens* 9 *e* 10.

- **Cirurgia plástica reparadora:** obrigação de **meio** (ex.: vítima de ataque de cachorro).
- **Cirurgia plástica meramente estética:** o entendimento dominante (e do STJ, ex.: REsp 1.180.815/MG) é de obrigação de **resultado**, com presunção de culpa.
- **Anestesia:** as anotações citam o anestesiologista como exemplo de obrigação de resultado, mas o ponto é controvertido; no livro, Léo a trata como obrigação de **meio** (veja o quadro abaixo).

Léo Vieira discorda: estética é obrigação de meio

Defende que a cirurgia meramente estética é **obrigação de meio**. A **pele é o maior órgão do corpo** e reage com **efeitos randômicos**, que impedem o médico de garantir o resultado.

Também rejeita o argumento de que ela merece **mais rigor** porque o paciente "entrou bem e não pode sair pior": a correção (ex.: orelha de abano) busca a **saúde psíquica**, que integra o conceito contemporâneo de saúde.

Léo Vieira no livro: meio, mesmo na estética e na anestesia

Estética: segue Aguiar Júnior, Azi, Forster e Kühn. Refuta os dois argumentos da maioria (Branco): a "**desnecessidade moral**" (só valia nos padrões antigos, quando a rinoplastia de Tagliacozzi foi vista como "sacrílega" em Bolonha; em 2001 o Brasil fez 350 mil cirurgias estéticas) e a "**inutilidade para a saúde**" (saúde é bem-estar físico, psíquico e social; a cirurgia pode ser "a senha para uma nova vida"). A pele tem comportamento imprevisível (Chabas); ninguém sabe por que o **queloide** aparece em uns e não em outros (Forster).

Ressalva: se o médico **garante o resultado** (por exemplo, com software de "antes e depois"), a obrigação passa a ser tratada como de resultado. E a estética exige cuidado ainda maior com informação e consentimento.

Anestesia: é de meio (com Kfouri Neto, contra França e Vasconcelos), pois ninguém garante que o paciente não terá hipersensibilidade a uma droga. Mas há obrigações de resultado dentro dela: **não abandonar** o paciente anestesiado e fazer o **exame pré-anestésico**.

Transfusão de sangue: também de meio, por causa da **janela imunológica** (testes podem não detectar contaminação recente pelo HIV). Critica Diniz, que reconhece a janela e mesmo assim fala em resultado.

Conclusão: concorda com Azi ("a obrigação do médico será sempre de meios"), com uma atenuação: só há obrigação de meio onde há **fator randômico**. Deveres como sigilo, informação e consentimento são de resultado.

SANTOS, 2008, *cap.* III, *item* 8.

9.4 Meio x resultado perdeu importância

A distinção importava porque, na obrigação de resultado, inverte-se o ônus da prova da culpa. Hoje o debate foi mitigado: o **art. 6º, VIII, do CDC** permite inverter o ônus, e o **art. 373, §1º, do CPC** positivou a **carga dinâmica da prova**, inclusive fora das relações de consumo. Na prática, juízes invertem o ônus seja a obrigação de meio ou de resultado, porque o médico tem mais facilidade de produzir a prova.

Art. 373, §2º, CPC: a decisão de redistribuir o ônus não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil (vedação da **prova diabólica**).

Léo Vieira no livro: meio x resultado e o ônus da prova

Defende a utilidade prática da distinção de **René Demogue** (sistematizada entre 1925 e 1930) contra Mosset Iturraspe e Kfouri Neto, que propunham abandoná-la. Na responsabilidade contratual subjetiva, só a obrigação de **resultado** inverte o ônus da culpa (presunção *juris tantum*).

Profissional liberal no CDC: a regra é o consumidor provar a culpa (art. 14, §4º), mas o juiz pode inverter o ônus no caso concreto (art. 6º, VIII), inclusive quanto a dano e nexo. Discorda de quem proíbe a inversão (porque presunção relativa não objetiva a responsabilidade) e de quem a torna automática (porque a lei deixa a decisão ao juiz). O momento adequado para inverter é o **saneamento**, para evitar surpresa e cerceamento de defesa.

SANTOS, 2008, *cap.* II, *itens* 8 *a* 10.

9.4.1 Por que a responsabilidade do médico não é objetiva

Léo Vieira no livro: a culpa continua sendo o fundamento

- **Art. 927, p. único, não se aplica:** ele adota o **risco criado**, e a medicina lida com **perigo**. Discorda de Gagliano e Pamplona, Rizzatto Nunes, Queiroga e Baú, que veem na medicina atividade de risco. Nem pelo risco-proveito: o paciente também busca o maior proveito (a vida e a saúde).
- **Art. 951 do CC:** só faria sentido regular a liquidação dos danos médicos para os casos de culpa se o legislador tivesse mantido a culpa como pressuposto (com Gonçalves).
- **Especialidade:** a cláusula geral do art. 927, p. único, não revoga a regra específica do art. 14, §4º, do CDC (com Cavalieri e Gagliano e Pamplona).
- **Direito comparado:** França, Alemanha, Portugal, Suíça, Itália, Espanha e Argentina mantêm a culpa (Kfouri Neto); nos EUA, o *Black's Law Dictionary* define *medical malpractice* como falha do médico em observar o cuidado que um médico da mesma especialidade usaria em circunstâncias similares; na Inglaterra, o **Relatório Pearson** concluiu pela manutenção da culpa.
- **Profissional liberal em obrigação de resultado** continua com responsabilidade subjetiva, só com inversão do ônus (com Nunes e Sanseverino; contra Diniz e Nery, que viam responsabilidade objetiva).

Responde à reação alarmada de entidades médicas ("os médicos foram colocados no paredão diante de um pelotão de fuzilamento"): imagine-se a reação dos advogados se respondessem por toda causa perdida, mesmo com a melhor técnica.

SANTOS, 2008, *cap.* III, *item* 10.

9.5 Iatrogenia

Dano provocado pelo médico, deliberadamente ou não, para evitar um mal maior. É uma **excludente de responsabilidade típica do direito médico**.

Exemplos

- O paciente fica careca e processa o médico; perde se o médico provar que ele tinha câncer e que a lex artis indicava quimioterapia, que faz o cabelo cair.
- O paciente sai amputado; a lesão é iatrogênica se havia putrefação da perna.

Léo Vieira no livro: iatrogenia e excludentes no direito médico

Distingue (com Couto Filho) a iatrogenia **lato sensu** (todo dano causado pela atuação médica, culposo ou não) da **stricto sensu** (lesão necessária para tentar curar um mal maior). Exemplos: amputação por diabetes ou gangrena; queda de cabelo na quimioterapia.

Discute o enquadramento: **não é exercício regular de direito** (contra Azi), pois adotar o melhor tratamento é um *dever* do médico; **não é força maior** (contra Couto Filho), porque muitas vezes não é absolutamente inevitável, e sim decisão técnica ponderada com o paciente; também não cabe no estado de necessidade (art. 929). Conclui que há "dificuldade de enquadramento", mas a iatrogenia é **indiscutível excludente de responsabilidade** típica do direito médico.

As demais "excludentes médicas" ("acidente imprevisível", "resultado incontrolável", "intercorrências") são, no fundo, **caso fortuito ou força maior** com vocabulário médico, pois o traço comum é a inevitabilidade.

SANTOS, 2008, *cap.* III, *item* 10.

9.6 Cirurgião-chefe

Responde **solidariamente** pelos atos da equipe (enfermeira, cirurgião auxiliar etc.). **Exceção: o anestesista**, que tem autonomia; o cirurgião não responde pelos problemas causados pelo anestesiologista.

9.7 Medicina defensiva

Alteração da prática médica motivada pelo receio de processos, e não pelo benefício ao paciente.

Tipo ou dimensão	O que é ou causa
Positiva	Exames e procedimentos excessivos para "blindar o prontuário".
Negativa	Recusa de pacientes de alto risco ou de procedimentos complexos.
Relação médico-paciente	Ruptura da confiança e fragilização do juramento hipocrático: o paciente deixa a "primeira prateleira" de prioridades e vira potencial adversário judicial.
Sustentabilidade	Encarece planos de saúde e sobrecarrega o SUS.
Iatrogenia	Expõe o paciente a riscos desnecessários.

9.8 Prescrição: 3, 5 ou 10 anos?

Campo	Prazo	Fundamento
Civil extracontratual	3 anos	**art. 206, §3º, V, do CC**.
Civil contratual	10 anos	**art. 205 do CC** (prazo geral), conforme tese do STJ.
Consumerista	5 anos	**art. 27 do CDC** (fato do serviço). É o prazo que o STJ aplica ao erro médico, por enquadrar a relação no CDC.

A tese do STJ (liderada pela Min. Nancy Andrighi): se o prazo para discutir a validade e o cumprimento de um contrato é de 10 anos, não seria razoável dar à parte apenas 3 anos para pedir a reparação decorrente desse mesmo contrato. A posição se consolidou não por súmula, mas por **julgamento de órgão colegiado**: **responsabilidade contratual = 10 anos**; **extracontratual = 3 anos** (STJ, 2ª Seção, EREsp 1.280.825/RJ, 2018; confirmada pela Corte Especial no EREsp 1.281.594/SP, 2019).

O problema no consumo: se o contratante "comum" tem 10 anos, seria estranho o consumidor, a parte vulnerável, ter prazo **menor** (5). Daí a **tendência doutrinária**, ainda **não consolidada**, de aplicar ao consumidor o prazo mais favorável (10 anos), inclusive ao paciente, se a relação com o médico for de consumo.

Termo inicial: actio nata

- **Actio nata objetiva** (regra, **art. 189 do CC**): o prazo corre da data em que o fato se concretiza no plano da realidade física (a violação do direito).
- **Na responsabilidade médica:** entende-se que o prazo corre da data em que o paciente toma conhecimento do dano (actio nata **subjetiva**). Ex.: compressa esquecida no abdômen; o prazo conta a partir de quando o paciente descobre a compressa.
- **Conclusão de aula:** é preciso **olhar o caso em questão**.

> **Base legal do termo inicial**
>
> Na relação de consumo, a regra do conhecimento está **na própria lei**: o **art. 27 do CDC** manda contar o prazo "a partir do conhecimento do dano e de sua autoria". No campo civil, o STJ aplica a actio nata subjetiva excepcionalmente, em casos como o erro médico descoberto depois.

> **Léo Vieira pensa diferente**
>
> As anotações registram apenas que o professor tem outro entendimento sobre o tema. Como, para ele, o **CDC não se aplica à relação médico-paciente** (item 11), o coerente é aplicar ao médico o regime do **Código Civil** (10 anos, se contratual; 3, se extracontratual), e não o debate dos 5 x 10 anos do consumidor.
>
> *Inferência a partir da posição de Léo no item 11; confirme com ele.*

9.9 Novos danos

- **Dano espiritual:** ex.: Testemunha de Jeová que recebe transfusão contra sua convicção.
- **Dano existencial:** a pessoa fica impedida de exercer atividade ou projeto de vida por causa da cirurgia.

10. Consentimento esclarecido

10.1 Origem

Até meados do século XX, o médico era "plenipotenciário". O marco da mudança foi a **Segunda Guerra Mundial**: os experimentos nazistas com prisioneiros (por exemplo, quanto frio ou calor o ser humano suporta), feitos sob a prerrogativa médica. Daí surgiu a ideia de que o paciente é senhor do próprio destino.

> **Precisão histórica**
>
> Nas anotações consta que a ONU criou o direito ao consentimento. O próprio livro do professor (citando Mônica Aguiar) indica os documentos corretos: o instituto foi desenvolvido pelo direito norte-americano a partir de 1950, como reação às experiências com prisioneiros nos campos de concentração e às da Guerra Fria, e consagrado no **Código de Nuremberg (1947)** e nas declarações da Associação Médica Mundial de 1964 e 1975 (**Helsinque I e II**). Em prova, cite esses documentos.

10.2 Conteúdo

O médico só pode praticar atos invasivos depois de colher o consentimento **esclarecido** do paciente (ou de familiares). Não basta o "ok": é preciso explicar prós e contras com linguagem compatível com o grau de instrução do paciente, para que ele decida. O paciente é "senhor do seu próprio destino".

Características: **continuado** (renovado a cada situação nova), **revogável** a qualquer tempo e **customizado** (adaptado ao perfil do paciente; se o paciente é médico, pode-se usar vocabulário técnico).

> ***Exemplo: a tetraplegia***
>
> O médico opera para conter tremores, sem informar que a cirurgia poderia levar à tetraplegia. O risco se concretiza, embora o médico não tenha agido com culpa técnica.

Base normativa: princípio da **autonomia** ("sobre seu corpo e sua mente, o indivíduo é soberano", John Stuart Mill); **arts. 13 e 15 do CC** (ninguém pode ser constrangido a tratamento com risco de vida); **arts. 6º, III, e 31 do CDC** (informação adequada sobre riscos); **art. 22 do Código de Ética Médica** (vedado deixar de obter o consentimento após esclarecer, salvo risco iminente de morte).

Léo Vieira x Alessandro Timbó

Léo: quando o médico atua sem consentimento esclarecido, sua responsabilidade **se objetiva**: dispensa culpa e pode haver condenação **até sem nexo causal**. Mesmo que prove perícia total e que o paciente caiu na mínima porcentagem de risco, responde **plenamente** pelos resultados negativos **previstos na literatura médica que de fato ocorreram** (o **prejuízo total**, sem valor arbitrado), como se tivesse agido com culpa, porque a consequência suportada (a tetraplegia) é a mesma. Essa visão **estimula o médico a sempre respeitar** o consentimento.

Timbó: trata-se de um **novo dano** (desrespeito ao consentimento). A responsabilidade não é objetiva, pois se discute a culpa do médico em não informar, e a indenização (por **danos morais**, arbitrada pelo juiz) deve ser **menor**, já que o procedimento foi correto. Para Léo, essa visão deixa os médicos negligenciarem o consentimento; segundo ele, na prática os médicos não querem "perder tempo" com esse ponto.

Observação do próprio professor: essa posição acadêmica contraria sua prática profissional, que é a defesa de médicos.

Léo Vieira no livro: a objetivação "por vias transversas"

A tese de aula já está no livro. Pergunta inicial: pode ser condenado o médico que operou com a melhor técnica e não causou dano corporal? **Sim**, se não colheu o consentimento.

- Os deveres de informar, confirmar a compreensão e colher o consentimento são **obrigações de resultado**. Por isso o **ônus de provar que informou é do médico**, e não por inversão judicial do art. 6º, VIII (discorda de quem fundamenta nas "portas fechadas" ou na hipossuficiência técnica).
- Sem consentimento, o médico responde por **todo dano** do tratamento, até o decorrente da álea da medicina, porque tirou do paciente a decisão de correr ou não o risco (com Diniz e C. Silva). Não se trata de transformar a obrigação em resultado: ele responde até

pela inexatidão da ciência. Sua defesa fica limitada a provar que não teve culpa por não ter obtido o consentimento.

- Mesmo sem dano corporal, cabe **dano moral puro** pela intervenção não consentida. Exemplo (C. Silva): o cirurgião contratado para esticar a pele do rosto decide, por conta própria, diminuir o nariz; o resultado fica até melhor, mas houve violação do direito de dispor do próprio corpo.
- O consentimento **não equivale a cláusula de não indenizar**: o médico ainda responde por erro culposo. E é **inválido** para procedimentos desnecessários ou com riscos desproporcionais, pois a integridade física é indisponível.
- Respeitar o consentimento é **profilaxia** contra ações judiciais.

SANTOS, 2008, *cap.* III, *item* 13.

10.3 Prova: o termo e a proposta de vídeo

O **ônus de provar o consentimento é do médico**. O **termo de consentimento**, escrito e customizado, é a prova usual, mas não a única: o consentimento pode ser verbal, se houver testemunha.

Proposta de Léo Vieira: videogravação

O termo escrito é **estático, genérico e técnico**, e muitas vezes é assinado sem explicação. Melhor seria **gravar em vídeo** a explicação (com o celular, arquivando em nuvem ou no prontuário eletrônico): permite ver linguagem, expressão corporal e compreensão do paciente.

O consentimento deve ser **continuado**: o paciente pode voltar atrás até a cirurgia, e fatos novos (um tumor descoberto durante a operação) exigem nova consulta, inclusive à família.

Léo Vieira no livro: a prova do consentimento

Já em 2008 sugeria, além de documentos individualizados, a **gravação da conversa** entre médico e paciente, ao menos onde houver recursos, como clínicas de cirurgia estética. Formulários padronizados assinados na entrada do hospital **não bastam** (França): ignoram o perfil do paciente, são genéricos e técnicos, e o tratamento envolve atos que não eram previsíveis no início. Com Sotto, sugere registrar no **prontuário** os nomes de quem assistiu ao diálogo de esclarecimento.

Revogável: o paciente pode mudar de ideia no meio do tratamento, salvo se a interrupção puser sua vida em risco. Se, durante uma cirurgia simples, surge problema mais complexo, o médico deve renovar o consentimento, salvo risco de vida (Aguiar Júnior).

Atos simples (engessar um braço, fazer um curativo): o consentimento é intuitivo, implícito, e dispensa maiores cuidados de prova.

SANTOS, 2008, *cap.* III, *item* 13.

Aprofundamento

Léo desenvolveu essa proposta em artigo de 2020, resumido no item 10.6.

10.4 Exceções

1. **Atos banais:** imobilização, aspirina. Remédios novos, para doenças raras ou mais graves exigem consentimento.
2. **Urgência ou emergência:** paciente com tiro no peito.
3. **Privilégio terapêutico:** revelar certas informações seria danoso ao paciente; o médico omite dele e informa a família (ex.: paciente com depressão grave e diagnóstico de câncer). Base: **art. 34 do Código de Ética Médica**.

10.5 Testemunhas de Jeová

Entendem que receber sangue de terceiros é pecado grave. A posição apresentada em aula: no conflito entre liberdade religiosa e vida, o médico deve **salvar a vida**; é melhor responder por constrangimento ilegal do que por homicídio.

Léo Vieira no livro: tratamento arbitrário e a "cruz e a espada"

O consentimento não é direito absoluto: diante de iminente perigo de vida, o princípio da **beneficência** prevalece sobre a autonomia, e o procedimento pode ser feito até contra a vontade do paciente ("tratamento arbitrário", Genival França). O médico fica "entre a cruz e a espada": terá de provar que o perigo era iminente; mas, se der "alta a pedido" e o paciente morrer, responde e pode ser acusado de omissão de socorro. Recomenda buscar a opinião de outros médicos e, se possível, o **Judiciário** (cita acórdão do TJRS autorizando a transfusão em Testemunha de Jeová).

SANTOS, 2008, *cap.* III, *item* 13.

Atualização jurisprudencial importante

Em **setembro de 2024**, o STF (RE 979.742 e RE 1.212.272, Temas 952 e 1.069, j. 25/9/2024) decidiu que o **adulto capaz** Testemunha de Jeová pode **recusar transfusão** por convicção religiosa, desde que a decisão seja inequívoca, livre, informada e esclarecida (inclusive por diretivas antecipadas de vontade), que haja viabilidade técnico-científica e concordância da equipe médica para o procedimento sem transfusão, e que o SUS deve oferecer tratamentos alternativos disponíveis. A recusa não vale em nome de filhos menores. Em prova, apresente a posição de aula e mencione esse entendimento do STF.

10.6 O artigo de Léo: videogravação do consentimento esclarecido

Texto: SANTOS, Leonardo Vieira. "Da (im)possibilidade de videogravação do consentimento esclarecido pelo médico nos contratos de tratamento". In: *Vida e legado jurídico de Antônio José Marques Neto* (e-book), Salvador: Direito Levado a Sério, 2020, p. 265-280.

> **Nome do livro**
>
> Nas anotações aparece "texto de José Marcos Neto". O homenageado do e-book é o professor **Antônio José Marques Neto**; o capítulo de Léo é o citado acima.

O problema: é jurídica e eticamente possível gravar em áudio e vídeo o momento em que o médico expõe "os prós e os contras" do ato e o paciente concorda? **A tese de Léo:** não só é possível, como é **recomendável** que vire prática habitual.

Ponto de partida: por que a prova do consentimento pesa tanto

O médico tem o **ônus de provar** que obteve o consentimento (art. 15 do CC; art. 22 do CEM, Res. CFM 2.217/2018). Quem age sem consentimento, ou não consegue prová-lo, "coloca sobre seus ombros o peso da incerteza da Medicina": responde **objetivamente**, mesmo que o dano decorra de complicação **estatisticamente prevista** na literatura e mesmo que não pudesse ser evitado. Léo chama isso de **responsabilidade civil objetiva agravada**.

Fundamento: o médico tirou do paciente, "senhor do seu próprio destino", a chance de decidir se queria correr os perigos do ato. Presume-se que, informado, ele poderia ter recusado e escapado do dano.

Exceções ao dever de informar: condutas simples ou corriqueiras, urgência ou emergência e **privilégio terapêutico** (quando a informação prejudicaria o paciente).

Cita Kfouri Neto: o consentimento informado logo será "o ponto central das discussões" sobre a responsabilidade do médico.

SANTOS, 2020, itens 1 e 2, p. 265-267.

Análise jurídica: nenhuma norma proíbe a filmagem

Condições propostas por Léo: a gravação é feita **pelo próprio médico**, em **local reservado**, **depois de o paciente ser informado e autorizar**, e o vídeo é **juntado ao prontuário**, sob sigilo. Também é lícito o paciente filmar, com a aprovação do médico.

Possível objeção	Resposta de Léo
Art. 5º, X, da CF (intimidade, vida privada, imagem)	Não é obstáculo. Arquivado no prontuário, o vídeo tem o **mesmo sigilo** do termo escrito; divulgá-lo é ilícito civil, ético e até crime (art. 154 do CP). E um prontuário eletrônico que registra cada acesso é **mais seguro** que papel.
Art. 20 do CC (uso da imagem)	A filmagem é **autorizada** e não atinge honra, boa fama ou respeitabilidade. Além disso, pode-se dizer que o registro é "necessário à administração da justiça".
Art. 11 do CC (irrenunciabilidade dos direitos da personalidade)	Se a autorização violasse direitos irrenunciáveis, o **termo escrito** também seria ilícito (ele traz nome e doença do paciente). Chegar-se-ia ao "diabólico absurdo" de impor ao médico o ônus da prova sem lhe dar meio razoável de cumpri-lo. Apoio: **Enunciados 4, 139 e 404 do CJF** (limitação voluntária, não permanente nem geral; tutela da privacidade com consentimento expresso para dados de saúde).
CDC	Mesmo que se aplicasse à relação, nada nele proíbe a filmagem; câmeras em estabelecimentos de consumo são corriqueiras. Em direito privado, **o que não é proibido é permitido**.
Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos (UNESCO, 2005)	O art. 6º, "a", trata de atos preventivos, diagnósticos e terapêuticos, não do procedimento de consentimento; o art. 9º (privacidade e confidencialidade) é respeitado pela gravação sigilosa.
Uso do vídeo em processo	O processo judicial ou ético que discuta o consentimento corre em **sigilo** (art. 89, §2º, do CEM; art. 1º do CPEP, Res. CFM 2.145/2016).
Quebra da confiança	Só se troca o meio de prova (termo estático por vídeo dinâmico); a essência do ato não muda. A resistência é **preconceito anacrônico**, ainda mais depois da telemedicina na pandemia (Lei 13.989/2020; Res. CREMEB 367/2020, que admitiu vídeos no prontuário).

Gravação escondida? Lícita, mas não recomendada

Pela jurisprudência do STF e do STJ, a gravação feita **por um dos interlocutores**, sem o conhecimento do outro, não é interceptação e é admitida como prova (STF, rel. Min. Ellen Gracie, RT 826/524; STJ, REsp 1.113.734/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2010). Seria ilícito apenas levá-la a terceiros.

Mas Léo não recomenda que médico ou paciente gravem às escondidas: numa relação de **extrema fidúcia**, a gravação clandestina contraria a **boa-fé objetiva** (art. 422 do CC) e o dever anexo de **transparência**.

SANTOS, 2020, *item 3, p. 270.*

E se o paciente recusar a filmagem?

Fora de urgência ou emergência, o médico pode recusar-se a prosseguir, como já se faz quando o paciente não assina o TCLE (muitos hospitais proíbem operar sem ele). Base: **art. 36, §1º, do CEM** (renúncia ao atendimento, com comunicação prévia e garantia de continuidade) e Capítulo II, IX (recusar atos contrários à consciência).

Contraponto: José Abelardo Garcia de Meneses (CREMEB), em evento da Fundação Orlando Gomes (2020), defendeu que o consentimento deve **incluir** o paciente, nunca excluí-lo. Léo concorda em parte: o médico não pode usar a primeira resistência como pretexto para se livrar do paciente, o que seria **abuso de direito** (**art. 187 do CC**). Deve insistir, de forma inclusiva, na explicação. Só se a recusa persistir pode encaminhar o paciente a outro profissional.

Boa-fé de mão dupla: fere a boa-fé o paciente que recusa a filmagem e depois tenta impor o procedimento, sabendo que o ônus da prova é do médico.

SANTOS, 2020, *item* 3, *p.* 271-273.

A quem interessa o vídeo? Aos dois lados

- **Ao médico:** provar que explicou adequadamente e escapar da responsabilidade objetiva agravada e de processos éticos.
- **Ao paciente:** provar que o médico não esclareceu os perigos; rever a explicação quando quiser e até **voltar atrás** antes do ato.
- **Efeito prático** (resposta à pergunta de Mônica Aguiar): os médicos que hoje fazem do consentimento um "**faz de conta**", com termos pré-formatados, seriam levados a fazer um consentimento **real**.
- **Semiótica:** o vídeo registra gestos, expressões e o vocabulário adequado ao paciente, o que o papel não mostra. "Indague-se a um magistrado ou a um conselheiro do CFM se ele preferiria decidir com base em uma folha de papel ou em um vídeo."

SANTOS, 2020, *item* 3, *p.* 272-275.

Análise ético-profissional: os pareceres dos Conselhos

Não há **resolução** do CFM ou dos CRMs que proíba a filmagem do consentimento. Há só **pareceres**, que são opinativos e **não têm força normativa** (ninguém é condenado por contrariá-los), e nenhum trata especificamente do consentimento esclarecido.

Parecer	Conteúdo	Por que não impede (Léo)
CFM 05/2016	Contra câmeras nas salas de atendimento de emergência.	Operadas por terceiros, sem autorização. Admite que imagens integram o prontuário e que não há resolução sobre o tema.
CFM 03/2011	Contra filmar perícias previdenciárias, salvo boa-fé, benefício e autorização do periciando.	A proposta pressupõe autorização.
CFM 47/2015 e 03/1999	Contra gravar cirurgias para auditoria e contra projeto de lei que obrigava a filmá-las.	Finalidade diversa (fiscalizar o médico).
CREMEB 12/2009; CRM-PR 2.609/2017	Admitem filmar atos médicos ou cirurgias com aquiescência do paciente.	**Reforçam** a tese.
CRM-SE 01/2018	Lícita a gravação pelo paciente com consentimento do médico.	Por coerência, vale o inverso.
CRM-MT 39/2019	Inseguro sobre filmar perícia judicial.	Relação perito-periciando é diferente.
CRM-MG 126/2019; CREMEB 07/2012 e 16/2015	Câmeras só em áreas de circulação; vedadas onde há atendimento (segurança, centros cirúrgicos e UTIs).	Tratam de monitoramento por terceiros; a filmagem pelo médico, autorizada, respeita autonomia (art. 24 do CEM) e sigilo.

Conclusão do artigo

É **absolutamente possível**, desde já, a videogravação do consentimento pelo médico: não há norma constitucional, legal, principiológica ou ético-profissional que a impeça, e ela deve virar **padrão** assim que possível, dada a superioridade do vídeo sobre o termo escrito.

Sugestão ao CFM: editar resolução que (a) **proíba** filmagens por terceiros, sem autorização, para auditorias ou fiscalizações que violem intimidade e sigilo; e (b) **autorize expressamente** a gravação do consentimento pelo médico, com concordância do paciente e arquivamento sigiloso no prontuário. A norma não é imprescindível, mas estimularia os reticentes e evitaria processos.

Não obrigatória: a maioria dos médicos trabalha em estruturas "arcaicas, precárias e carentes de recursos". A proposta é que **quem puder** filmar, filme.

SANTOS, 2020, *item* 5, *p.* 279.

Atualizações depois do artigo (2020)

- A Lei 13.989/2020 (telemedicina na pandemia) foi **revogada** pela **Lei 14.510/2022**, que disciplina a **telessaúde** de forma permanente. A CFM regulamentou a telemedicina na Res. 2.314/2022.
- A **LGPD** (em vigor desde 2020) classifica dados de saúde como **sensíveis** (art. 5º, II; art. 11); o vídeo do consentimento é dado sensível, o que reforça os cuidados de sigilo e segurança defendidos no artigo (ver item 14).

II. CDC e a relação médico-paciente

Relação	Natureza
Paciente × hospital	**Consumerista** (pacífico).
Paciente × médico	**Debatida**: o STJ aplica o CDC; Léo e Timbó defendem que não se aplica.

Entendimento dominante (STJ): o CDC se aplica à relação médico-paciente. A divergência de Léo é só quanto à relação médico-paciente (não quanto a hospitais, por exemplo).

Contexto da advocacia: as duas turmas de direito privado do STJ (3ª e 4ª) chegaram a divergir sobre aplicar o CDC à relação advogado-cliente; hoje o entendimento consolidado é que **não se aplica**. Foi a partir dos fundamentos desses julgados que Léo construiu a analogia com a medicina.

Léo Vieira é contra (posição minoritária)

Analogia com a advocacia: o STJ consolidou que o CDC **não se aplica** à relação advogado-cliente, porque (1) o **Estatuto da Advocacia** forma um microssistema próprio, posterior ao CDC; e (2) a advocacia **não pode ser mercantilizada**: a sociedade é registrada na OAB e não na junta comercial, a fidúcia é maior e a publicidade é restrita, enquanto no consumo "a propaganda é a alma do negócio".

Fora a questão da lei específica (a Lei do Ato Médico, Lei 12.842, é de 2013), **todos esses argumentos valem para a medicina, até com mais força**: o juramento hipocrático e as normas éticas vedam a mercantilização; se o objeto é a vida humana, o lucro não pode vir em primeiro lugar (princípio bioético da **beneficência**).

Incompatibilidades do CDC com a medicina (ambas no art. 40 do CDC, que exige orçamento prévio com valores e com as "datas de início e término dos serviços"):

- **Orçamento:** o cirurgião não tem como orçar com precisão, porque cada organismo é individual e reage de um jeito.
- **Data de término:** não há como dizer quando o tratamento vai acabar; isso varia muito e faz parte da **idiossincrasia** da medicina.

- **Miguel Kfouri Neto** usa o art. 14, §4º, do CDC para defender que a responsabilidade do médico não é atingida pelo regime do CDC.
- **Alessandro Timbó** invoca o direito comparado: a Alemanha, matriz romano-germânica do nosso direito, afastou a aplicação consumerista. Ele apresentou proposta legislativa sobre o tema (questão *de lege ferenda*, "da lei a ser feita"). Detalhes no item 11.1.
- O STJ hoje responde que, diferentemente da advocacia, não há lei específica sobre a responsabilidade médica. Há pouquíssimos julgados afastando o CDC (segundo o professor, apenas um no STJ).

> **Evolução do pensamento do professor**
>
> No livro de 2008, Léo analisava a responsabilidade do médico **dentro do CDC**, com a exceção do art. 14, §4º (culpa do profissional liberal), e não pregava excluir os hospitais do CDC. A defesa da **inaplicabilidade do CDC à relação médico-paciente** aparece nas aulas e converge com o artigo de Alessandro Timbó, que cita o livro de Léo. Em prova, apresente a posição atual (aula).

11.1 O artigo de Alessandro Timbó

Alessandro Timbó Nilo (médico e advogado), "A natureza jurídica da relação paciente-médico e a (in)aplicabilidade do CDC na resolução das demandas cíveis".

Consequências práticas do enquadramento consumerista (Farias, Rosenvald e Braga Netto)

- Inversão do ônus da prova em favor do paciente (**art. 6º, VIII**), que na prática objetiva a responsabilidade do médico.
- Foro do domicílio do consumidor (**art. 101, I, CDC**), seja onde for o atendimento.
- Prescrição de 5 anos (**art. 27**), em vez de 3 (**art. 206, §3º, V, CC**).
- Dever de informação "particularmente severo" (**arts. 6º, III, 8º e 9º**).
- Nulidade de cláusulas que excluam ou atenuem o dever de indenizar (**art. 51, I**), o que pode levar o médico a responder por iatrogenia.

Argumentos pela inaplicabilidade

- **A vida não tem preço** (Sandel): saúde não é mercadoria; o médico não tem o lucro como objetivo principal, ao contrário do empresário (Fábio Ulhoa Coelho).
- **Incompatibilidade com o CDC:** o art. 39, XII, considera abusivo não fixar prazo para a obrigação, mas o médico não pode garantir o fim de um tratamento nem condicionar o atendimento de urgência a acordo prévio.
- **Código de Ética Médica:** Princípio IX ("a Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio"); Princípio XX ("a natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza relação de consumo"); vedação ao exercício mercantilista; vedação à propaganda comercial; dever de atender urgência e emergência mesmo sem contrato ou pagamento.
- **Analogia com a advocacia:** o STJ afasta o CDC da relação advogado-cliente (REsp 532.377, 539.077, 757.867, 914.105 e 1.134.889) por um critério formal (o Estatuto é lei federal específica). Mas o Código Civil tem artigos específicos da relação paciente-médico (**arts. 15, 948, 949, 950 e 951**), e o CDC não tem nenhum. A Lei do Ato Médico (Lei 12.842/2013, art. 2º) repete que o alvo da atenção do médico é a saúde do ser humano.
- **Precedente:** a 4ª Turma do STJ, no **REsp 466.730/TO** (2008, voto-vista do Min. Massami Uyeda), afastou o CDC numa cirurgia de catarata que causou cegueira. Mas a decisão não explicitou a *ratio decidendi* e por isso não firmou precedente.
- **Medicina defensiva:** o enquadramento consumerista estimula médicos a "hiperinformar" pacientes só para se proteger, desvirtuando o consentimento.
- **Nome da relação:** Timbó escreve "paciente-médico", porque a iniciativa é sempre do paciente (o médico não pode fazer propaganda) e para valorizar sua autonomia.

O modelo alemão: o "contrato de tratamento" (BGB, §§ 630a a 630h)

Incluído pela "Lei para melhorar os direitos dos pacientes" (*Patientenrechtegesetz*), em vigor desde 26/2/2013:

Parágrafo	Conteúdo
630a	Deveres típicos; o tratamento deve seguir os padrões médicos geralmente reconhecidos no momento do tratamento (a lex artis).
630b	Aplicam-se as regras da prestação de serviços, mas não as trabalhistas.
630c	Cooperação: o dever de informar é **bilateral**; o médico deve informar diagnóstico, prognóstico e terapia e, a pedido ou para evitar risco, revelar circunstâncias que indiquem erro de tratamento.
630d	Consentimento prévio; em urgência, segue-se a vontade presumida do paciente; o consentimento é revogável a qualquer tempo, sem forma e sem justificativa.
630e	Esclarecimento oral, em tempo hábil e compreensível, incluindo riscos, alternativas e chances de sucesso; o paciente recebe cópia do que assinou; pode ser dispensado em urgência ou por renúncia expressa.
630f	Prontuário contemporâneo ao tratamento; correções identificadas; guarda por 10 anos.
630g	Acesso do paciente (e dos herdeiros) ao prontuário.
630h	Presunções legais: erro quando se materializa risco totalmente gerenciável pela equipe; ônus do médico de provar consentimento e esclarecimento; medida não registrada presume-se não realizada; falta de qualificação presume-se causa do dano; **erro grosseiro** presume-se causa da lesão.

Proposta de Timbó

- A relação teria a natureza de um "**affectio societatis especial**": paciente e médico perseguem um fim comum (a saúde), e não interesses contrapostos como numa locação de serviços. O contrato está mais próximo dos aleatórios, em que a álea atinge ambos.
- **De lege lata:** enquadrar a relação no Código Civil, com o Código de Ética Médica como parâmetro, aplicando o CDC só excepcionalmente: quando houver prática mercantil ou antiética (promessa de resultado estético, propaganda irregular), com comunicação ao CRM. Quando a ação é contra o **hospital** por erro de médico do seu quadro, a análise continua pelo CDC (art. 14, §4º).
- **De lege ferenda:** tipificar o "contrato de tratamento" no Código Civil, como na Alemanha, ou elevar o Código de Ética Médica a lei ordinária. Cita Kfouri Neto: "de lege data, os médicos, enquanto profissionais liberais, não se sujeitam às normas do CDC, em relação aos atos terapêuticos".

> **Atenção à versão do Código de Ética**
>
> Timbó cita a Resolução CFM 1.931/2009. O código vigente é a **Resolução CFM 2.217/2018**, que manteve os princípios citados (IX e XX) e o art. 22 sobre consentimento.

12. Responsabilidade civil dos hospitais

As incertezas da relação médico-paciente se aplicam aos hospitais. Mas é ainda mais difícil sustentar que o CDC não se aplica a eles, que buscam lucro. Ao mesmo tempo, exercem função social relevante.

12.1 Bipartição de deveres (José de Aguiar Dias)

Dever	Conteúdo	Regime
Hospedagem	Estrutura: quarto, cama, alimentação, segurança.	**Objetiva** (art. 14, caput, CDC), com ressalvas.
Assistência médica propriamente dita	Atividade que só ocorre sob liderança ou participação do médico.	Divergência (três correntes abaixo).

Léo Vieira no livro: a hospedagem é obrigação de resultado

No dever de hospedagem, as obrigações são em regra de **resultado**, e a responsabilidade é **objetiva** (art. 14, caput, CDC): alimentação adequada ao estado do paciente (dieta para diabéticos) e nos horários; instalação de comissão de controle de infecção e limpeza; **dever de incolumidade** (quedas do leito, abusos sexuais, agressões); manutenção de equipamentos; enfermeiros nos postos.

Enfermagem: o que define o regime é a natureza da obrigação, e não discutir se o enfermeiro é profissional liberal (discorda de Cardoso). Deixar de trocar as **fraldas geriátricas**: resultado, responsabilidade objetiva. **Curativos** pós-cirúrgicos e demora na cicatrização: meio, exige prova de que a técnica de enfermagem não foi observada. Discorda também de Aguiar Júnior, que via toda a hospedagem como obrigação de meio.

SANTOS, 2008, *cap. IV, item 8.*

Ressalvas à responsabilidade objetiva na hospedagem (aula):

1. **Enfermeiros e demais profissionais de saúde:** parte do que fazem envolve as idiossincrasias do organismo humano; não dá para aplicar responsabilidade objetiva a tudo.
2. **Infecção hospitalar:** muitas vezes é trazida pelo próprio paciente e ocorre nos melhores hospitais; não existe hospital sem infecção. Se ela não pôde ser contida apesar das cautelas devidas, há caso fortuito ou força maior. Na prática, avalia-se se as condutas do hospital foram determinantes, ou seja, avalia-se culpa.
3. **Serviços paramédicos** também são apontados como exceção à responsabilidade objetiva.

12.2 Assistência médica: três correntes

Corrente	Tese	Ônus da prova
1. Consumerista radical (Herman Benjamin, coautor do CDC)	Objetiva e ponto final: art. 14, caput, do CDC, sem exceções. Basta provar dano e nexo.	Sem discussão de culpa.
2. Contra legem (Miguel Kfouri Neto e Rui Stoco)	Contorna o caput do art. 14: o que se analisa é a atuação do médico; sem culpa do médico, o hospital não é condenado. Aplica a lógica do art. 932 (responsabilidade do empregador pelo empregado). Inspirada em um *leading case* do TJSP. Argumento: na corrente 1, um hospital de câncer seria processado o tempo todo.	Regra geral: o paciente prova os fatos constitutivos, inclusive a culpa. Na prática, a carga dinâmica tem invertido quase sempre.
3. Defeito do serviço (Sergio Cavalieri Filho, autor de obra de perfil fortemente objetivista, no polo oposto a Rui Stoco)	Não é "objetiva e ponto final", mas a corrente 2 também não procede. O art. 14 exige um requisito: o **defeito do serviço**.	Inversão **ope legis**: cabe ao hospital provar que não houve defeito (art. 14, §3º, I).

Leitura de Léo Vieira sobre as correntes

Crítica à corrente 3: o conceito de defeito do serviço hospitalar remete à culpa, porque para avaliá-lo é preciso avaliar a conduta do médico.

Mesmo na corrente 1, o debate sobre a conduta do médico **migra para o nexo causal**: a defesa argumenta que o médico usou o melhor da técnica e o paciente morreu mesmo assim, logo o resultado era inevitável, e a inevitabilidade quebra o nexo.

Léo Vieira no livro: adere à corrente de Stoco e Kfouri

No livro, Léo **adere à corrente 2** (Stoco, Kfouri Neto, Aguiar Júnior): no dever de assistência médica, a responsabilidade do hospital exige a **culpa do médico**. "Todos os caminhos levam" à análise da conduta do médico pela lex artis:

- **Corrente 2:** pela incompatibilidade lógica entre **obrigação de meio e responsabilidade objetiva**. O hospital não promete cura; objetivar seria fazê-lo responder pelo que não prometeu (Stoco, Azi).
- **Corrente 1 (Benjamin):** pelo elo entre **nexo e culpa**: a previsibilidade é elemento dos dois; para saber se a morte era inevitável é preciso verificar se o médico fez tudo o que a lex artis indicava, ou seja, apurar culpa. Até Rizzatto Nunes, que defende a objetivação total, admite exigir o nexo.

- **Corrente 3 (Cavalieri):** porque o "**defeito**" do serviço médico, medido pela "segurança que se pode esperar" e pelo "estágio técnico" (Benjamin), só se apura pela conduta do médico. Aponta contradição em Cavalieri, que nega a objetivação das obrigações de meio no art. 927, p. único, e usa justamente a cirurgia do idoso como exemplo. A "diferença sutil" entre culpa e defeito (Sanseverino) nunca é explicada.
- **Art. 13 do CDC por analogia** (Saulo Casali Bahia): o hospital seria mero intermediário do ato médico, com responsabilidade subsidiária. Léo acha o argumento pertinente, mas favorável demais aos hospitais.

Art. 933 do CC: só acabou com a discussão sobre culpa *in eligendo* e *in vigilando* do empregador (Súmula 341 do STF); a vítima ainda precisa provar a **culpa do preposto**. Confirmação: **Enunciado 191 da III Jornada de Direito Civil** ("A instituição hospitalar privada responde, na forma do art. 932, III, do CC, pelos atos culposos praticados por médicos integrantes de seu corpo clínico").

Leading case do TJSP (citado por Kfouri): em ação contra hospital com base no CDC, "a ela não se aplica a responsabilização objetiva, na medida em que o que se põe em exame é o próprio trabalho médico".

Incoerência que aponta: o banco de sangue responderia *subjetivamente* pelo funcionário que se contamina com HIV no trabalho e *objetivamente* pelo receptor contaminado por causa da janela imunológica. Também seria injusto o hospital responder objetivamente sem poder exercer regresso contra o médico que, com autonomia (arts. 8º e 16 do antigo Código de Ética), conduziu o procedimento.

Diferença prática entre as correntes: só o ônus da prova. Na de Cavalieri, o hospital prova a ausência de defeito (art. 14, §3º); nas outras, o paciente prova a culpa, salvo inversão judicial.

SANTOS, 2008, *cap.* IV, *item* 7.

Corpo clínico aberto

Se o médico é estranho ao hospital e apenas decide internar ali o seu paciente, o hospital não responde pelo ato desse médico.

Léo Vieira no livro: o médico estranho ao hospital

O Código de Ética garante ao médico o direito de internar e assistir seus pacientes em hospitais privados, mesmo sem integrar o corpo clínico, respeitadas as normas da instituição. Como o hospital não pode impedir essa atuação, **não responde** pela culpa desse médico (com Gonçalves, Stoco e Azi; contra Gagliano e Pamplona). Analogia: seria como obrigar o dono do carro requisitado pela polícia para perseguir um assaltante a indenizar os danos da perseguição. Ressalva: o hospital responde se o dano vier de **defeito estrutural** seu, como falha de equipamento.

SANTOS, 2008, *cap.* IV, *item* 9.

Conclusões e propostas do livro

- Médicos e hospitais respondem de forma **subjetiva** pelos serviços médicos propriamente ditos, porque assumem obrigação de meio.
- A teoria **objetiva** fica reservada às obrigações de **resultado** (como a hospedagem) e ao desrespeito ao **consentimento esclarecido**.
- **Propostas:** (a) autonomia do **Direito Médico** como disciplina; (b) uma **lei específica** que reúna as normas sobre médicos e hospitais, com hospitais respondendo solidariamente com os médicos, sempre com base na culpa, "até que a medicina deixe de ser uma ciência inexata"; (c) um **seguro de responsabilidade civil médica**, se a sociedade decidir que o paciente não deve suportar sozinho a álea.

SANTOS, 2008, *Conclusão*.

13. Funções da responsabilidade civil

Visão clássica: a responsabilidade civil é sanção de caráter reparador (e, reflexamente, preventivo), com foco em **reparar o dano**; daí alguns países a chamarem de "direito de danos". Pela lógica do art. 944, o direito positivo não admite usá-la para fins exclusivamente punitivos ou preventivos.

Autor seminal da **multifuncionalidade**: **Nelson Rosenvald**, para quem a visão só reparatória é restrita e insuficiente. Há propostas no projeto do novo Código Civil e texto do ministro Edson Fachin (presidente do STF) sobre o tema, que também tem repercussão jurisprudencial. O professor indicou um vídeo do **IBERC** (Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil), em que cada professor apresenta uma das funções. Esse webinar está resumido na **Parte III** (item 16).

Função	Ideia	Posição de Léo
Reparatória	Tradicional e secular, de raiz no Código francês: trazer o patrimônio da vítima de volta ao *status quo*.	—
Preventiva	Evitar o dano. Já existia de forma reflexa.	Valoriza a reflexa; resiste à responsabilidade civil sem dano.
Punitiva	Punir o autor além da extensão do dano (*punitive damages*).	Contra, salvo danos em massa com culpa grave.
Promocional	Premiar quem age de forma exemplar e repara o dano.	Discorda; nada concreto ainda.
Restitutória	Retirar do ofensor o lucro obtido com o ilícito.	Função disruptiva; critica o nome.

13.1 Função preventiva

> **Ligação com a prova**
>
> A **responsabilidade proativa da LGPD** é a face mais visível da função preventiva. Veja a questão de prova no item 14.11.

A condenação muda a conduta do próprio condenado e, de forma **reflexa**, desestimula outras pessoas a repetir aquele comportamento. Há quem a trate como **"supraprincípio"**: mais importante que reparar seria evitar o dano.

Léo Vieira discorda de Rosenvald

Valoriza muito a função preventiva **reflexa**, mas resiste à **responsabilidade civil sem dano**: abrir mão do dano como pressuposto é "demais". Nosso ordenamento não é pródigo em normas que fundamentem prevenção independentemente de dano. Situações de perigo podem ser atacadas e até sancionadas por normas específicas, mas isso não precisa ser chamado de responsabilidade civil.

13.2 Função punitiva

Tem raízes no direito norte-americano (*common law*): a condenação não fica limitada à extensão do dano (ex. citado em aula: Johnny Depp x Amber Heard, em que o júri fixou indenização punitiva além da compensatória). Seus defensores afirmam que o foco é contemplar as vítimas, e não só reprovar a conduta. Defendida no Brasil por Cláudia Lima Marques e Fernanda Ivo; criticada por Thiago Borges.

> Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
> Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Léo Vieira: punitive damages só em danos em massa

Concorda com Thiago Borges: nosso sistema é incompatível com o dos EUA; punir é papel do direito penal (**não há pena sem lei prévia**). Pelo **art. 944**, a indenização mede-se pela extensão do dano, e o parágrafo único só permite **reduzir**. Se o legislador quisesse a função punitiva, teria previsto ali; por isso, defendê-la no Brasil é doutrina **contra legem**.

Exceção que aceita: danos em massa com **culpa grave**, quando a empresa calcula que é mais barato pagar indenizações do que corrigir o problema. Pela AED, a punição muda a planilha de custos e torna mais vantajoso corrigir. Nas relações do dia a dia, é **veementemente contra**.

> **Sobre o exemplo citado**
>
> O caso clássico de empresa que calculou que era mais barato indenizar do que corrigir é o **Ford Pinto** (Grimshaw v. Ford, 1981). O caso **McDonald's** (Liebeck, 1994) é o do café servido quente demais, mantido apesar de centenas de reclamações de queimaduras. Ambos ilustram *punitive damages*.

Graus de culpa (aferidos pela pessoa média)

- **Grave:** erro que a pessoa média não cometeria de jeito nenhum; aproxima-se do dolo.
- **Leve:** erro que a pessoa média não cometeria, mas não tão acintoso.
- **Levíssima:** erro tênue, que até a pessoa média poderia cometer.

> **Atenção ao sentido do brocardo**
>
> *In lege Aquilia et levissima culpa venit* significa, literalmente, que na lei Aquília **até a culpa levíssima** gerava o dever de indenizar. A conclusão anotada em aula (a culpa levíssima não basta) é a **crítica** a esse brocardo, defendida no livro do professor (abaixo).

Léo Vieira no livro: a culpa levíssima não basta

A gradação da culpa vem do direito romano, perdeu importância com o CC/16 e **ressurgiu** com o **art. 944, p. único, do CC/02**. Com Maria Celina Bodin de Moraes, afirma que o brocardo **não sobreviveu ao direito romano**: como hoje a culpa é aferida em abstrato pelo padrão do **homem médio**, e não do "diligentíssimo pai de família", a culpa levíssima (que o homem médio também cometeria) **não gera dever de indenizar**, nem na responsabilidade extracontratual. Só a culpa leve ou grave configura a responsabilidade subjetiva.

Definições (M. Rocha): **grave**, omissão evitável com capacidade ordinária e sem esforço de atenção (*culpa lata dolo aequiparatur*); **leve**, evitável com atenção ordinária; **levíssima**, só evitável com habilidade transcendente.

Art. 944, p. único, também na responsabilidade objetiva: discorda de Gagliano e Pamplona. Se o legislador quisesse afastar a redução equitativa nos casos de responsabilidade objetiva, o teria dito. Com Fábio Ulhoa Coelho: o empresário responde objetivamente, mas não é justo tratar igualmente o relapso e o cuidadoso; a diligência pode reduzir o valor.

SANTOS, 2008, *cap.* II, *item* 6.

13.3 Função promocional

O oposto da punitiva: premiar quem, mesmo tendo causado dano, age de forma exemplar e repara o que causou.

> **Importante (aula)**
>
> A função promocional é a **menos impactante** de todas. O próprio Antônio dos Reis Júnior, que a sistematizou, a chama de a "mais neófita" das funções (item 16.4).

Léo Vieira discorda

Não há nada concreto; é uma ideia que pode frutificar, mas é questão **de lei a ser feita**. Nem o projeto de 2025 a incorporou, ao contrário das funções preventiva e restitutória.

13.4 Função restitutória

Proposta por Rosenvald para os ilícitos lucrativos: pela teoria clássica, o ofensor paga o prejuízo e ainda sai lucrando. Inspirada no direito comparado, abre **três caminhos**, que são **excludentes entre si** (a vítima escolhe um só):

Caminho	Foco
1. Teoria clássica	Extensão do dano da vítima.
2. Disgorgement ("vomitar" o lucro)	O ofensor devolve o lucro obtido com o ilícito. Disruptivo: em vez de levar a vítima ao *status quo*, leva o **ofensor** ao estado anterior.
3. Reasonable fee (taxa razoável)	O juiz fixa o valor razoável que seria pago por uma licença de uso (ex.: uso da imagem).

Exemplo de aula: uso indevido da imagem de Giovanna Antonelli por uma revista

Clássica: o valor do prejuízo dela. Disgorgement: o lucro que a revista obteve com a edição. Reasonable fee: quanto a revista teria pago para usar a imagem licitamente.

Precedente positivado: art. 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; II - os benefícios auferidos pelo autor da violação; III - a remuneração que o autor da violação teria pago pela concessão de licença.

A lei trata isso como lucros cessantes; Rosenvald propõe estender a lógica a toda a responsabilidade civil, deslocando o foco do patrimônio da vítima para o do causador do dano.

Léo Vieira sobre a restitutória

Considera a função **disruptiva** e acha o **nome errado**, pois "restituir" remete à ideia de reparar. Mas reconhece que a expressão já foi consagrada pelo uso.

14. Responsabilidade civil na LGPD

Aula de 29/10 ministrada por ***Raquel Dortas****, sócia do professor no escritório (slides "Responsabilidade Civil na LGPD"). Esta seção segue a ordem dos slides; os textos complementares (Guia da ANPD, artigo de Walter Capanema e a pesquisa de jurimetria) entram onde dialogam com cada slide.*

14.1 Privacidade e direitos da personalidade

- **Privacidade:** tudo aquilo referente ao íntimo do indivíduo, à sua vida pessoal, ao que é privado.
- **Direitos da personalidade:** preservam a individualidade de cada pessoa e abrangem a integridade **física** (corpo, alimento), **psíquica** (sociabilidade, privacidade) e **moral** (honra, intimidade).
- **Redefinição da privacidade:** no início, era a **não ingerência** na vida privada, familiar, na correspondência e nas comunicações. Com a cultura tecnológica, a **hiperconectividade** e a formação de um "corpo eletrônico", a esfera privada ficou mais complexa e, ao mesmo tempo, mais frágil e exposta. Daí a ampliação do conceito para o direito à autodeterminação informativa: o direito de escolher quais dados serão usados, com quais limites e por quanto tempo (Danilo Doneda, citado por Capanema). É **fundamento** da LGPD (**art. 2º, II**), e não princípio.

14.2 A proteção no Brasil e a criação da LGPD

- **CF/88, art. 5º, X:** intimidade e vida privada invioláveis, conceitos que o constituinte usou para definir privacidade. A proteção de dados trata diretamente da vida privada e ganha "relevância máxima" na sociedade globalizada.
- **Contexto internacional:** status de direito fundamental em diplomas internacionais; na Europa, o **Regulamento Geral (RGPD ou GDPR)**, que inspirou a LGPD.
- **Antes da LGPD:** CDC, Marco Civil da Internet, Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/2011) e Lei de Acesso à Informação tratavam do tema de forma **difusa e insuficiente**.
- **LGPD (Lei 13.709/2018):** regulação geral do tratamento de dados, pautada em princípios éticos e na autodeterminação informativa.

> *Complemento*
>
> Desde a **EC 115/2022**, a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, é direito fundamental expresso (**art. 5º, LXXIX, CF**).

14.3 Os cinco pilares da LGPD

Publicada em agosto de 2018, a lei regula o tratamento de dados pessoais, **online ou offline**, com base em:

1. **fundamentos** alinhados aos valores constitucionais;
2. **conceitos** técnicos para a correta aplicação da lei;
3. **princípios** que servem de baliza interpretativa;
4. **deveres de conduta** e regras específicas para os agentes de tratamento;
5. **direitos dos titulares** e uma autoridade central para fiscalizar e regulamentar (**ANPD**).

14.4 A quem se aplica (art. 3º)

Ao tratamento feito no Brasil, com dados coletados no Brasil, ou que tenha por objetivo ofertar bens ou serviços ou **monitorar o comportamento** de pessoas localizadas no Brasil, independen-

temente da nacionalidade ou residência. Atinge, portanto, também empresas estrangeiras que atuam no mercado brasileiro.

Finalidade econômica: uso de dados numa atividade de produção, circulação ou oferta de bens e serviços, obtenção de vantagens patrimoniais, geração de receitas ou promoção de interesses econômicos, **ainda que sem lucro direto ou imediato**. Quando a finalidade é **exclusivamente particular** (esfera pessoal ou doméstica), a LGPD não se aplica (**art. 4º, I**).

A LGPD protege **pessoas naturais**; não é uma lei voltada à proteção de dados de pessoas jurídicas (anotação de aula).

14.5 Conceitos (art. 5º)

Conceito	Definição
Dado pessoal	Informação relacionada a pessoa natural **identificada ou identificável**. Ampla proteção à dimensão existencial da pessoa.
Dado sensível	Dado que pode gerar especial vulnerabilidade, sobretudo **discriminação**: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical ou a organização religiosa, filosófica ou política, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico (inciso II).
Tratamento	Toda operação com dados pessoais: coleta, recepção, utilização, acesso, reprodução, transferência, processamento, armazenamento, eliminação, entre outras (inciso X).

14.6 Princípios (art. 6º)

Os slides agrupam: **finalidade, adequação e necessidade**; **livre acesso e qualidade**; **transparência e não discriminação**; **segurança e prevenção**; **responsabilização e prestação de contas**.

> **Responsabilização e prestação de contas** (art. 6º, X): "demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas".

14.7 Personagens da LGPD

1. Titular

Pessoa natural a quem se referem os dados (**art. 5º, V**). É o **núcleo da existência da LGPD**, que o protege de violações à liberdade, à privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade.

2. Agentes de tratamento

	Controlador (art. 5º, VI)	Operador (art. 5º, VII)
Quem é	Pessoa natural ou jurídica a quem competem as **decisões** sobre o tratamento (elementos essenciais). Pode ou não tratar diretamente.	Pessoa natural ou jurídica que **realiza o tratamento em nome do controlador**, só nos limites das finalidades definidas por ele.
Exemplos (ANPD)	Médica profissional liberal que guarda prontuários no computador do consultório; loja que organiza um sorteio; site de venda de livros.	Agência de publicidade contratada para a campanha; call center terceirizado; empresa de cartão ou fintech que processa o pagamento.

Principal diferença: o poder de decisão. Segundo o Guia da ANPD, o controlador decide os **elementos essenciais** (finalidade, base legal, natureza dos dados, duração e prazo de eliminação); o operador pode decidir só **elementos não essenciais** (ex.: softwares e medidas técnicas).

- **Caráter institucional:** numa pessoa jurídica, quem é agente é a **organização**, que responde pelos atos dos seus prepostos perante os titulares e a ANPD. **Empregados, sócios, administradores e servidores não são agentes de tratamento**. Ex.: médica empregada de hospital que assina o contrato de armazenamento em nuvem: o controlador é o hospital, e não ela.
- **Setor público:** o controlador é a pessoa jurídica (ex.: a União), mas o órgão (ex.: um Ministério) exerce as funções típicas de controlador (nomear encarregado, comunicar incidentes). A ação judicial do titular vai contra a União.
- **Analogia de Capanema:** numa leitura civilista, o controlador seria o mandante e o operador, o mandatário.

3. Controladoria conjunta e suboperador

- **Controladoria conjunta:** dois ou mais controladores determinam em conjunto as finalidades e os meios do tratamento (art. 26 do RGPD). Pela ANPD, exige: (1) mais de um controlador com poder de decisão; (2) interesse mútuo sobre o mesmo tratamento; (3) decisões **comuns ou convergentes**. Respondem **solidariamente** os controladores diretamente envolvidos no tratamento danoso (art. 42, §1º, II). Ex.: empresas ARGENTINA e BRASIL lançam um produto de marca conjunta e decidem juntas o evento e os convidados. Não há controladoria conjunta se cada um usa os mesmos dados (ex.: dados abertos de uma agência) para fins próprios.
- **Suboperador:** contratado pelo operador para executar parte do serviço que o controlador contratou. Pode ser equiparado ao operador quanto às atividades que executa, **ampliando a cadeia de responsabilidade solidária**. Ex.: ALPHA (controladora) contrata a pesquisa da BRAVO (operadora), que contrata armazenamento em nuvem da CHARLIE (suboperadora). A ANPD recomenda que o operador obtenha **autorização formal** do controlador para subcontratar.
- **Encarregado (DPO):** canal de comunicação entre controlador, titulares e ANPD (art. 41). Pode ser funcionário ou agente externo, pessoa física ou jurídica. A responsabilidade continua do

controlador ou operador; Capanema admite responsabilização solidária do encarregado externo numa relação de consumo, por integrar a cadeia de fornecimento.

> ***Como identificar o controlador (perguntas do slide)***
> Quem decide coletar? Quem decide a finalidade? Quem decide quais dados serão tratados? Quem obtém lucro ou vantagem? Quem tem relação direta com os titulares? Quem tem autonomia sobre o tratamento? Quem nomeia terceiros para tratar dados em seu nome?
> **Contexto do tratamento:** o agente é definido **para cada operação**. A mesma organização (ou profissional liberal) pode ser controladora numa operação e operadora em outra. Ex. da ANPD: a filial brasileira YANKEE é operadora da campanha decidida pela matriz, mas controladora da folha de pagamento dos seus empregados.

14.8 Principais obrigações dos agentes

Obrigação	*A quem se aplica*
Medidas técnicas de segurança; medidas jurídicas; medidas administrativas; prestação de contas	Controlador e operador
Notificação de incidentes (art. 48); relatório de impacto (art. 38); resposta às solicitações dos titulares (art. 18); indicação de encarregado (art. 41); prova de que o consentimento foi válido (art. 8º, §2º)	Controlador

> Art. 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria.

14.9 O sistema de responsabilidade civil (base dos slides)

Teoria clássica: "reparação de danos injustos resultantes da violação de um dever geral de cuidado"; "obrigação de reparar danos injustos que se infringe por culpa ou em certos casos determinados por lei". Mas a responsabilidade civil não se resume a reparar danos:

- **Princípios:** dignidade da pessoa humana, solidariedade, prevenção e reparação integral.
- **Funções basilares:** reparatória (compensação), punitiva e de precaução.

Subjetiva (art. 927, caput)	*Objetiva (art. 927, p. único)*
Ato ilícito (arts. 186 e 187): antijuridicidade + imputabilidade. **Culpa ou abuso de direito**: condutas comissivas ou omissivas, com dolo, negligência ou imprudência. **Dano**: lesão a interesse concretamente merecedor de tutela. **Nexo causal**. **Nexo de imputação**: o ato ilícito.	**Fato**: ato ou **atividade** (processo; reiteração calculada de atos, não ocasional, para certa finalidade, que por sua natureza produz danos em escala anormal). **Dano**. **Nexo causal**. **Nexo de imputação**: o **risco da atividade** ou a lei.

Teoria do risco da atividade: risco próprio, inerente, que produz danos em escala anormal; investiga-se objetivamente a ligação entre o risco da atividade e o dano. Pergunta-chave: *a atividade, em seu exercício, criou um risco a outrem?*

14.10 Os arts. 42 a 45 da LGPD

> Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

O slide qualifica o art. 42 como hipótese de **ato ilícito**, ligada aos princípios de **segurança**, **prevenção** e **responsabilização e prestação de contas**.

Elemento do art. 42	*Leitura dos slides*
"em razão do exercício de atividade de tratamento"	O regime é delimitado pela **atividade lesiva**, e não pelo interesse lesado ou por uma condição especial do titular: incide sobre **qualquer dano** decorrente do tratamento de dados.
"dano patrimonial, moral, individual ou coletivo"	Lesão a interesse juridicamente protegido, **atual, real e certo** (suscetível de prova, art. 402 do CC). Exige-se **juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade**.
"em violação à legislação de proteção de dados"	Violação de deveres jurídicos: culpa normativa.

"Legislação de proteção de dados" (Capanema): é um microssistema, com a LGPD como base, que inclui leis e normas administrativas (da ANPD, do Banco Central etc.), por analogia com a "legislação tributária" do art. 96 do CTN. Para ele, há duas fontes de responsabilidade: **(a)** violação de normas **jurídicas**; **(b)** violação de normas **técnicas** de segurança (ex.: padrões ISO 27001), por força do **art. 44, p. único**. Em ambos os casos, só há responsabilidade se houver **dano**.

Controlador e operador

- **Alocação de responsabilidade** conforme o contrato e as obrigações estipuladas; na falta, as normas legais. Pesa também o contexto do compartilhamento e a natureza da relação com os titulares (consumo, cível, trabalhista; agente privado ou público).
- Se o operador descumpriu determinação do controlador, cabe incluí-lo na lide ou exercer regresso, e é possível sustentar a **responsabilidade exclusiva do operador**, pedindo a exclusão do controlador.
- **Sem cláusulas contratuais** sobre alocação de responsabilidade, a responsabilização em caso de incidente será **solidária**, ainda que o operador tenha agido dolosamente.
- **Operador (art. 42, §1º, I)** responde solidariamente se: (1) descumprir a legislação de proteção de dados; ou (2) não seguir as instruções lícitas do controlador, caso em que se **equipara ao controlador**. Para a ANPD, essa é uma excepcionalidade: em regra, a responsabilidade é do controlador. Capanema compara ao mandatário que descumpre as instruções do mandante (**art. 679 do CC**).

Ônus da prova, tratamento irregular e segurança

- **Art. 42, §2º:** o juiz pode **inverter o ônus da prova** a favor do titular (verossimilhança, hipossuficiência ou prova excessivamente onerosa); teoria dinâmica (**art. 373, §1º, CPC**). **A quem compete provar a conformidade? Ao agente de tratamento.**
- **Art. 44:** o tratamento é **irregular** quando (1) deixa de observar a legislação (culpa normativa) ou (2) não fornece a segurança que o titular pode esperar, considerando: o **modo** como é realizado; o **resultado e os riscos** que razoavelmente se esperam; as **técnicas disponíveis à época**. Há correlação entre a regularidade da atividade e o avanço tecnológico da época.
- **Art. 44, p. único:** responde pelos danos da violação da segurança quem, ao deixar de adotar as medidas do art. 46, der causa ao dano. É hipótese adicional de responsabilidade e reforça a importância das medidas técnicas.
- **Art. 46:** medidas de segurança, técnicas e administrativas, contra acessos não autorizados; situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação; e qualquer tratamento inadequado ou ilícito.
- **Art. 45:** nas relações de consumo, aplica-se o **CDC**.

> ***Segurança é obrigação de meio (Capanema)***
>
> - Se o dano decorreu de **vulnerabilidade já conhecida e documentada** (catálogos como o CVE) que não foi corrigida, fica evidenciada a **negligência** do agente.
> - Se o ataque explorou uma **vulnerabilidade "0-day"** (ainda não documentada), seria incabível responsabilizar: não se pode exigir segurança contra o que ninguém conhece. O dever é segundo o **estado da técnica à época**.
> - Conclusão do autor: a obrigação de segurança é **de meio**, não de resultado; nenhum agente garante 100% de segurança.

Excludentes (art. 43)

Os agentes só não serão responsabilizados quando provarem:

1. que **não realizaram o tratamento** que lhes é atribuído (Capanema: aproxima-se da ilegitimidade passiva, mas a LGPD a trata como mérito);
2. que, embora tenham realizado o tratamento, **não houve violação à legislação** (dano por ato lícito; ex. de Capanema: decisão automatizada com critérios transparentes e sem viés que nega um empréstimo);
3. que o dano decorre de **culpa exclusiva do titular ou de terceiro**. Pergunta de Capanema: se a conta de e-mail é invadida porque o titular usava senha de quatro caracteres, há culpa exclusiva dele, ou o agente deveria impedir senhas fracas?

14.11 Natureza do dever de indenizar: o debate

A LGPD não deixa claro se a regra é subjetiva, objetiva ou proativa. Nas relações cíveis (fora do consumo), há três correntes:

Corrente	Argumento
Subjetiva	É a regra geral (art. 927 do CC). A LGPD não diz que todo tratamento de dados é atividade de risco, e o art. 43, II, exclui a responsabilidade se não houve violação à legislação.
Objetiva	Leitura conjunta dos arts. 42 e 44: incidentes de segurança relacionam-se ao risco inerente ao tratamento de dados e devem ser vistos como intrínsecos à atividade.
Proativa	Olha a responsabilidade de modo positivo: exige posturas preventivas dos agentes; a indenização é medida excepcional. **Para Léo, não é terceiro gênero** (veja a questão de prova abaixo).

Posição da aula: culpa presumida relativa

Reflexões do slide:

- Se o risco de qualquer atividade virar fator de imputação, compromete-se a livre iniciativa e o empreendedorismo: **solidariedade e liberdade devem coexistir**.
- O art. 43, II, manda **perquirir o comportamento do agente**.
- O único dispositivo do projeto que previa responsabilidade objetiva foi **retirado** na tramitação: o histórico legislativo evidencia a opção pela responsabilidade subjetiva.
- Os arts. 46 a 54 trazem **standards de conduta** (segurança, sigilo, boas práticas e governança). Por que fixar parâmetros de conduta se o agente respondesse pelo simples exercício da atividade?

Conclusão do slide: pelo art. 43, o controlador será sempre responsabilizado, salvo se faltar **nexo causal** ou **antijuridicidade**. O sistema da LGPD é o da **culpa presumida em caráter relativo**, e não o da responsabilidade objetiva pura: o agente afasta a responsabilidade demonstrando que adotou os **deveres de cuidado** definidos pela lei.

Na aula do professor (14/11): fora do consumo, a responsabilidade é subjetiva; pela AED, não seria justo condenar quem fez tudo o que estava ao seu alcance. Quanto à relação entre controlador e operador, Léo entende que não há norma na LGPD que libere o controlador provando boa escolha e fiscalização do operador (culpa *in eligendo* e *in vigilando*, linha europeia); aplica-se subsidiariamente o **art. 932, III, do CC**.

⚠ QUESTÃO DE PROVA (alerta do professor: vai cair)

Na LGPD, fala-se em "responsabilidade proativa" como um terceiro tipo ao lado da responsabilidade subjetiva e da objetiva. Conceitue a responsabilidade proativa e diga se ela é, de fato, um terceiro gênero.

Estude junto com: o seminário sobre as funções da responsabilidade civil (item 13), sobretudo a **função preventiva** (13.1).

Modelo	*O que exige*
Subjetiva	Culpa (dolo ou culpa em sentido estrito), que precisa ser **comprovada** para haver condenação.
Objetiva	Risco da atividade e nexo causal: responde pelo dano **independentemente de culpa**.
Proativa	A empresa deve adotar **salvaguardas antes que o problema ocorra** (segurança, governança, prestação de contas); ligada à **função preventiva** da responsabilidade civil e ao princípio de responsabilização e prestação de contas (**art. 6º, X**).

Posição de Léo Vieira: parte da doutrina apresenta a responsabilidade proativa como **terceiro gênero**. Para Léo, **não é bem isso**. Ela está atrelada a um **dever jurídico**: os controladores devem ter uma conduta **contínua e protetiva** dos dados, sob pena de sofrer as **sanções da ANPD** (art. 52). Não é um terceiro regime ao lado dos outros dois: é um dever **autônomo** que **complementa** a responsabilidade subjetiva e a objetiva.

Em suma: a responsabilidade da LGPD é **subjetiva**, e a proativa **se aproxima da subjetiva**. O que se demonstra no processo é que o agente não adotou as medidas que deveria, isto é, que tratou os dados de forma **negligente**: isso é **culpa em sentido estrito**.

Roteiro de resposta:

1. Apresente a dúvida da LGPD: a lei não define o regime; há quem fale em subjetiva, objetiva e proativa (item 14.11).
2. Conceitue as três, como na tabela.
3. Ligue a proativa à função preventiva (Rosenvald) e aos arts. 6º, X, 46 a 50 (segurança e boas práticas).
4. Exponha a crítica de Léo: não é terceiro gênero, mas dever jurídico autônomo e complementar, cuja violação gera sanção da ANPD.
5. Conclua: a responsabilidade civil da LGPD é subjetiva (retirada da regra objetiva no projeto; art. 43, II; standards de conduta). Provar a falta de salvaguardas é provar negligência, ou seja, culpa. Ressalve: nas relações de consumo, aplica-se o CDC (art. 45); a aula fala em culpa presumida em caráter relativo.

Texto em sentido contrário ao slide

Walter Capanema (Cadernos Jurídicos da EPM, 2020) afirma que a responsabilidade da LGPD é **objetiva**, como reconhecimento da hipossuficiência do titular. Isso diverge da conclusão da aula (culpa presumida relativa). Curiosamente, o próprio Capanema diz que a obrigação de segurança é de **meio** e que o 0-day afasta a responsabilidade, argumentos que aproximam sua análise da posição do slide. Em prova, siga a aula e mencione a divergência.

14.12 Consumidores e Administração Pública

Relação	Regime
Consumo	A responsabilidade objetiva é mais evidente: aplica-se também o CDC (art. 45 LGPD + arts. 12 a 14 CDC). Teoria do **risco do negócio**: o risco fica com o empreendedor.
Administração Pública: atos comissivos	Objetiva (teoria do risco administrativo).
Administração Pública: atos omissivos	Subjetiva (ex.: omissão de cautela quanto à segurança).

14.13 Sanções administrativas (art. 52)

Aplicadas pela ANPD, que exerce atividade fiscalizatória e sancionadora: advertência; multa simples (até 2% do faturamento, limitada a R$ 50 milhões por infração); multa diária; publicização da infração; bloqueio e eliminação dos dados; suspensão e proibição, parcial ou total, das atividades de tratamento. As sanções administrativas não afastam a responsabilidade civil.

14.14 Quanto indenizar (Capanema)

Pelo art. 944 do CC, a indenização mede-se pela extensão do dano, considerando: (a) a **quantidade** de dados afetados; (b) a **natureza** dos dados (sensíveis valem mais, sobretudo biométricos, que não podem ser trocados); (c) a **reincidência**; (d) a omissão em adotar medidas para reduzir o dano ou em colaborar com a ANPD; (e) a ausência de **notificação** do incidente aos titulares (art. 48); (f) o uso comprovado dos dados vazados por terceiros.

Exemplos de responsabilidade (Capanema)

- **Vazamentos** (bancários, senhas, biometria): o dano aumenta com o uso posterior dos dados por criminosos.
- **Não atendimento dos direitos do titular** (art. 18: acesso, correção, eliminação, portabilidade etc.): pode gerar dano moral, cumulável com dano material.
- **Spam:** em 2009, o STJ (REsp 844.736/DF) negou indenização por e-mails publicitários não solicitados, por ausência de previsão legal. Com a LGPD, enviar mensagens exige base legal (consentimento ou outra), e esse entendimento precisa ser revisto.

14.15 Jurimetria: como os tribunais têm decidido

Pesquisa apresentada na aula (amostra concentrada entre 2023 e 2026, com predomínio de TJSP e STJ, relações de consumo e contratos bancários).

Julgado	Entendimento
STJ, 2ª T., **AREsp 2.130.619/SP** (2023)	Vazamento de dados **comuns** não gera dano moral presumido; é preciso provar o dano. Diferencia dados comuns de sensíveis.
STJ, 3ª T., **REsp 2.121.904/SP** (2025)	Vazamento de dados **sensíveis** (fiscais, bancários e de saúde) em seguro de vida: responsabilidade objetiva e dano moral presumido.
STJ, 3ª T., **REsp 2.133.261/SP** e **REsp 2.115.461/SP** (2024)	Distinguem *credit scoring* dos bancos de dados da Lei 12.414/2011: disponibilizar dados cadastrais e de adimplemento a terceiros sem autorização pode gerar responsabilidade objetiva e dano presumido (R$ 11 mil no primeiro).
STJ, 3ª T., **REsp 2.206.924/SP** (2025)	Comercialização indevida de dados por banco de dados: dano moral presumido.
STJ, 3ª T., **REsp 2.077.278/SP** (2023)	Na fraude bancária, a responsabilidade do banco depende de provar o vazamento ou o nexo entre a falha de segurança e o golpe.
STJ, **REsp 2.187.854/SP** (2025)	Dano moral presumido quando a fraude foi viabilizada por vazamento de dados sigilosos (parcelas, valores, financiamento).
STJ, 4ª T., **AgInt no AREsp 2.170.495/SP** (2025)	Ato de terceiro **não rompe automaticamente** o nexo: o agente deve provar medidas de segurança adequadas e culpa exclusiva do terceiro.
TJSP, Ap. 1041607-35.2021 (2022)	R$ 10 mil pelo uso comercial não autorizado de dados sobre **gravidez** (dado sensível).
TJMG (2021, 2024 e 2026)	Ora afasta a culpa de terceiro por falha de segurança da empresa; ora nega indenização por falta de prova do vazamento e do nexo; ora acolhe o art. 43, III, quando provada a culpa exclusiva do terceiro.
TJRS (2026)	Uso de nome, CPF e RG em cadastro: sem dano automático. Divulgação de fotos e vídeos **íntimos**: dano *in re ipsa*.

Tema 1.404 do STJ (pendente)

Afetado em 2025 pela Segunda Seção (ProAfR no REsp 2.226.097/SP), com suspensão dos processos. Vai definir: (1) se é lícito que gestores de bancos de proteção ao crédito disponibilizem ou comercializem dados **não sensíveis** a terceiros sem comunicação ou consentimento prévio; e (2) se essa ilicitude gera **dano moral in re ipsa**. Pode uniformizar a divergência entre "prova do dano" e "dano presumido".

Síntese das tendências

1. **Não há resposta uniforme sobre dano presumido:** dados comuns isolados exigem prova; dados sensíveis, íntimos ou financeiros têm maior aceitação do dano presumido; dados usados em fraude geram dano presumido quando provado que o vazamento viabilizou o golpe.

2. **O nexo causal virou o principal ponto de disputa:** quais dados os fraudadores tinham; se eram exclusivos do controlador; se coincidiam com informações contratuais; se houve fraude; se o agente adotou medidas adequadas; se o terceiro foi causa exclusiva ou só se aproveitou da falha.
3. **Dados sensíveis recebem proteção reforçada** (saúde, gravidez, vida sexual, saldos, limites, financiamentos).
4. **Relações de consumo ampliam a proteção:** o art. 45 preserva o CDC, articulado com os arts. 42 e 44.
5. **O art. 43 exige prova do rompimento do nexo:** alegar ataque hacker ou fraude não basta.

Valores: em casos individuais, em geral entre **R$ 5 mil e R$ 11 mil**, maiores em exposição íntima ou consequências graves.

> **Cuidado ao citar**
>
> A própria pesquisa recomenda conferir o inteiro teor, a autenticidade e a situação processual de cada julgado antes de usá-lo em peça.

14.16 Bibliografia indicada sobre proteção de dados

1. DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*.
2. LEONARDI, Marcel. *Tutela e privacidade na internet*.
3. BIONI, Bruno Ricardo. *Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento*.
4. MENDES, Laura Schertel. *Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo direito fundamental*.
5. RODOTÀ, Stefano. *A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje*.
6. DE LUCCA, Newton; LIMA, Cíntia Rosa Pereira de; SIMÃO FILHO, Adalberto; MACIEL, Renata Mota (coords.). *Direito e Internet IV: sistema de proteção de dados pessoais*.
7. MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo; SARLET, Ingo Wolfgang; RODRIGUES JR., Otavio Luiz (coords.). *Tratado de proteção de dados pessoais*.
8. OPICE BLUM, Renato. *Proteção de dados: desafios e soluções na adequação à lei*.
9. HOFFMANN-RIEM, Wolfgang. *Teoria geral do direito digital*.
10. OLIVEIRA, Ricardo Alexandre de; COTS, Márcio Eduardo Riego. *O legítimo interesse e a LGPD*.
11. TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. *Dados pessoais sensíveis: qualificação, tratamento e boas práticas* (2022).

> **Atualização sobre o Guia da ANPD**
>
> O Guia de Agentes de Tratamento usado nesta seção é a versão 2.0 (abril de 2022), que dizia não haver ainda registro obrigatório do encarregado. Depois, a ANPD regulamentou a atuação do encarregado (Resolução CD/ANPD nº 18/2024). Confira a versão vigente do guia antes de citá-lo.

15. Responsabilidade civil na internet

A internet nasceu com finalidade militar e acadêmica e se espalhou, sobretudo com os celulares. Cristiano Chaves chega a defender o acesso à internet como **direito da personalidade**; a exclu-

são digital prejudica a integração social (ex.: reconhecimento facial na Arena Fonte Nova). Para o professor, o saldo da internet é positivo.

15.1 Casos que motivaram a legislação

- **Daniela Cicarelli:** vídeo íntimo gravado por paparazzo numa praia foi publicado; houve ação contra Google e YouTube. O pedido de danos morais não prosperou, com o argumento de que ela se expôs em local público. As **astreintes** (multa diária de R$ 250 mil pelo descumprimento da ordem de retirada, que ficou dias sem ser cumprida) foram reduzidas pelo juiz (por volta de 2010), tema que gera questões milionárias.
- **Carolina Dieckmann:** divulgação de fotos íntimas levou à **Lei 12.737/2012**, de natureza penal.
- Esses casos reforçaram a criação do **Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)**.

15.2 Quem causa o dano diretamente

A internet "não é terra de ninguém", e não há regra específica para quem causa o dano diretamente: aplica-se a **teoria geral**. Quem faz comentário ofensivo responde, seja ou não o autor da publicação, numa rede social, num jogo on-line ou na seção de comentários de um site. Há decisões responsabilizando o **administrador de grupo** de WhatsApp por danos ocorridos no grupo (responsabilidade indireta) e quem **curte ou compartilha** conteúdo ofensivo. O dano mais comum é o moral, mas quem ofende pode responder também por dano moral, e pode responder por **lucros cessantes** (acusar alguém falsamente de pedofilia pode gerar prejuízo milionário), **danos materiais** (gastos com propaganda para desmentir) e **dano existencial**.

> ### Prova: ata notarial (art. 384 do CPC)
> É o meio de prova "padrão ouro": o tabelião, com fé pública, atesta que o conteúdo estava na internet com aquele teor. **Prints** têm valor discutível para muitos juízes, inclusive pela possibilidade de manipulação por IA. Desvantagem da ata: o custo. Também serve à defesa: no caso de um médico processado após uma cirurgia, a esposa dele encontrou no Instagram elementos que ajudaram na defesa, e isso pôde ser registrado em ata notarial.

15.3 Plataformas: o regime do Marco Civil

O legislador buscou equilíbrio: evitar censura, não sancionar as plataformas a ponto de travar a inovação, mas também não liberá-las de todo dever. Resultado: responsabilidade subjetiva e mitigada das plataformas (Google, Meta, portais).

- **Regra (art. 19):** a plataforma só responde se, após **ordem judicial** de retirada, não remover o conteúdo.
- **Exceção (art. 21):** conteúdo de **nudez ou atos sexuais** de caráter privado divulgado sem autorização: basta a **notificação** da pessoa envolvida, sem ordem judicial, sob pena de responsabilidade. Os casos das duas atrizes citados acima se encaixariam nessa exceção: bastaria o requerimento ao Google.

15.4 A decisão do STF (2025)

A lei de 2014 envelheceu diante de fatos como pedofilia, ataques à democracia, uso da internet para influenciar eleições e organização de ataques a escolas. Com o Congresso travado pela pola-

rização, o STF julgou o tema (Temas 987 e 533, RE 1.037.396 e RE 1.057.258, em 26/6/2025, por 8 a 3) e declarou o **art. 19 parcialmente inconstitucional**, admitindo que agiu pela inércia do Legislativo.

Situação	*Regime após a decisão*
Crimes contra a honra	Mantém-se a exigência de **ordem judicial** (art. 19), sem prejuízo de a plataforma remover após notificação extrajudicial.
Demais crimes e atos ilícitos (pedofilia, atentados ao Estado Democrático, ataques a escolas etc.)	Basta a **notificação** de qualquer pessoa, sem ordem judicial: a lógica que valia para nudez foi estendida.
Conteúdos gravíssimos (atos antidemocráticos, terrorismo, induzimento ao suicídio, discriminação, crimes contra a mulher, crimes sexuais contra vulneráveis, tráfico de pessoas)	Dever de cuidado: a plataforma deve torná-los indisponíveis de imediato e responde se houver **falha sistêmica**. Um conteúdo isolado não basta.
Anúncios e impulsionamentos pagos; robôs	Responsabilidade **presumida**, mesmo sem notificação; a plataforma se exime provando atuação diligente.
E-mail, mensageria privada, reuniões fechadas	Continua valendo o art. 19 para comunicações pessoais.

As plataformas alegam que a decisão tem feição de norma e pedem prazo de adaptação (cerca de 6 meses), o que o professor considera razoável. Hoje existe IA capaz de fazer esse filtro. Com o novo entendimento, cresce o debate sobre responsabilidade **objetiva**, seja pelo CDC, seja pelo dever de manter sistemas de filtragem. A decisão vale para frente (modulação), ressalvadas as decisões já transitadas em julgado.

> ***Atenção: o que a tese do STF diz sobre responsabilidade objetiva***
>
> A própria tese afirma expressamente que **não haverá responsabilidade objetiva** na sua aplicação. O regime continua subjetivo, embora mais rigoroso (presunções e falha sistêmica). A exceção são os **marketplaces**, que respondem pelo CDC. Em prova, apresente o debate de aula, mas registre o texto da tese.

Material complementar indicado pelo professor

Parte III · Palestra: as funções da responsabilidade civil

16. Webinar IDP · IBERC (2020)

Evento: "As funções da responsabilidade civil", Grupo de Pesquisa O Direito Privado no Século 21 (IDP e IBERC, 2020). É o vídeo do IBERC indicado em aula (item 13). Moderação: Profa. Marília, magistrada do IDP.

> ***Sobre a fonte***
>
> O material de base é uma **transcrição automática**, com trechos truncados. Nomes, artigos e números foram conferidos quando possível; o que não pôde ser confirmado está marcado. São **posições de doutrina**, não regras legais: em prova, escreva "segundo [autor]". E lembre que **Léo diverge** de boa parte delas (item 13 e quadro do item 16.6).

16.1 A tese comum: de monofuncional a polifuncional

A responsabilidade civil deixa de ser **monofuncional** (só reparar) e passa a ser **polifuncional**: além de reparar, previne, pune, remove ganhos ilícitos e estimula a reparação espontânea. A função **reparatória** continua sendo a primária, e ninguém a questiona.

Por que "só reparar" não basta (Rosenvald)

- Quase nenhum dano chega a ser compensado: a maioria dos casos esbarra na prova do nexo causal ou no anonimato do dano.
- Quando há compensação, muitas vezes quem paga é o **seguro**, e o efeito sobre a conduta do ofensor some.
- Nem toda vítima quer dinheiro: nas ofensas a direitos da personalidade, há tendência de "**desmonetização**" da reparação.
- Na responsabilidade objetiva, a análise da conduta desaparece; sem juízo de reprovação, sobra só a conta.

> ***Método: análise estrutural x funcional (Reis Júnior)***
>
> A análise **estrutural** pergunta "o que é?" (elementos e requisitos). A **funcional** pergunta "para que serve?". O evento inteiro usa a segunda pergunta. Para Reis, a finalidade global da responsabilidade civil é **contornar o dano**, e há várias maneiras de fazer isso.

Momento	Função	Tipo de sanção
Antes do dano	**Preventiva** (Thaís)	Positiva ou negativa
Com o dano	**Reparatória** (função primária)	Recompõe o dano
Depois do ilícito	**Punitiva** (Fernanda) e **restitutória** (Rosenvald)	Negativa (castigo; remoção do ganho)
Depois do dano	**Promocional** (Reis)	Positiva (prêmio)

16.2 Thaís Pascoaloto Venturi: função preventiva

Autora de *Responsabilidade civil preventiva* (2014). A transcrição grafa "Thaís Pasqualotto".

> ### Em uma frase
> A prevenção não é só uma função: é o **fundamento** da responsabilidade civil contemporânea, que precisa olhar para o futuro, e não apenas para o dano que já ocorreu.

- **O retrovisor:** com imagem atribuída a Geneviève Viney, o sistema clássico olha o dano "pelo retrovisor": ele já aconteceu e só resta reparar. Hoje se exige uma **responsabilidade de antecipação**, que previne o dano, o ilícito ou o risco.
- **Ética da responsabilidade** (provavelmente Hans Jonas; a transcrição está truncada): quem age deve prever as consequências possíveis de suas decisões. "Responsabilizar" já significou só reprimir; hoje significa também agir prevendo.
- **Função, princípio ou fundamento?** Para uns, é uma função entre outras; para outros, um princípio que rege toda a matéria. Para Thaís, é **fundamento**: a responsabilidade civil é instrumento de direcionamento de condutas, e a prevenção aparece **dentro de todas as funções** (a perspectiva de pagar molda condutas; a punição educa; a promoção premia; a precaução evita o risco incerto).
- **Por que agora:** crescimento dos danos em quantidade e qualidade (ex.: *fake news* como dano coletivo e sistêmico, capaz de comprometer o processo eleitoral) e ampliação do que se considera dano (criança sem cinto, *bullying*). Ressalva: não existe sociedade sem dano; a prevenção **complementa** a reparação, não a substitui.
- **Análise Econômica do Direito:** o maior benefício social das regras de responsabilidade é **prevenir**, não compensar (para compensar, o seguro é melhor). Marcos: Calabresi, *The costs of accidents*, e Calabresi e Melamed, "Property rules, liability rules, and inalienability" (*Harvard Law Review*, v. 85, 1972). Ideia-chave: fazer o agente **internalizar as externalidades**. Limites do seguro: nem todos podem contratar o facultativo, e o obrigatório socializa demais o prejuízo.
- **Proposta: tutela inibitória material.** No Brasil, a tutela inibitória foi estudada quase só pelo processo civil (Marinoni), o que dá a impressão de que ela só nasce depois da violação. Thaís propõe mecanismos preventivos **no próprio direito civil**: astreintes, caráter punitivo-pedagógico, autotutela e despesas preventivas.
- **Caso: MP 966/2020** (responsabilidade de agentes públicos na pandemia, inspirada no **art. 28 da LINDB**, que fala em erro grosseiro). O STF (rel. Min. Barroso) fixou que configura **erro**

grosseiro o ato que viola vida, saúde ou meio ambiente por inobservância dos princípios da **precaução e da prevenção**, e que a autoridade deve exigir que os pareceres técnicos tratem expressamente desses princípios.

> ***Conferir antes de citar***
>
> O artigo do CC sobre autotutela saiu truncado na transcrição; os candidatos naturais são os **arts. 249, p. único, e 251, p. único** (o credor que, em urgência, executa ou desfaz por conta própria e cobra depois). O repetitivo de dano ambiental citado é o Tema 707 (REsp 1.374.284/MG).

Crítica ao rótulo "direito de danos": o foco passou do ofensor para a vítima, mas é preciso pensar na pessoa **antes** de ela virar vítima. Olhar só para a vítima ignora o agente que escolhe o ilícito porque ele compensa. "Nem tanto ao céu, nem tanto à terra."

16.3 Fernanda Ivo Pires: função punitiva

Doutora pela PUC-SP; autora de *Responsabilidade civil e o efeito punitivo da reparação* (2014).

> ***Em uma frase***
>
> O direito civil pode punir, e isso não é invasão do direito penal: a **pena privada** responde a uma exigência de eficácia social.

- **Base:** os princípios do Código de Reale, **eticidade** (valor da pessoa), **socialidade** (indivíduo e coletividade) e **operabilidade** (direito que funciona), formam a **função social** da responsabilidade civil, da qual prevenir, reparar e punir são facetas. Citando Renan Lotufo, o direito civil deveria ser feito "pelo povo e para o povo".

Crítica	Resposta de Fernanda
"Punir é coisa do direito penal"	O direito civil sempre teve penas: **cláusula penal**, possuidor de má-fé que perde benfeitorias úteis sem indenização, regras de acessão. E ele "atinge onde mais dói": o patrimônio.
"É cópia dos EUA"	Estudar direito comparado não é transplantar. Itália, Espanha e França discutem a ideia; o Código Civil do **Quebec** prevê a punição. Cita Paolo Gallo (pena privada).
"Cria a indústria do dano moral"	Estudos norte-americanos dos anos 1980-90 mostram que o número de ações não cresceu de forma relevante; poucos casos de valor altíssimo puxavam a média. Existe mais uma "indústria da lesão".
Enriquecimento sem causa da vítima	A causa existe: é a **ilicitude** do ofensor.
Art. 944 do CC	Não se aplica ao dano moral (não há "extensão" mensurável de uma lesão à personalidade). E se o parágrafo único permite **reduzir** por equidade, por que não aumentar?

- **Para quem vai o valor?** Parte da doutrina quer destinar a parcela punitiva a **fundos**. Fernanda defende que reverta à **própria vítima**, daí "pena *privada*" (posição minoritária).
- **Culpa:** a responsabilidade objetiva é fundamental, mas não deve ocupar todo o espaço; falar de punição é falar de **culpa e de sua graduação**.
- **Conceito de dano:** perda de um **equilíbrio relacional** (contratual, existencial ou patrimonial). A punição da falta de cuidado e da violação da boa-fé faz parte do reequilíbrio.
- **Súmula 7 do STJ:** os tribunais declaram o caráter punitivo-pedagógico, mas não têm coragem de "pesar na caneta"; o juiz de 1º grau modera por medo de reforma, o STJ não revê fatos e os valores não mudam: um "cachorro correndo atrás do rabo".

Contraste com Léo Vieira

Léo cita Fernanda Ivo como defensora da função punitiva, mas **discorda**: com Thiago Borges, vê a tese como **contra legem** diante do art. 944, cujo parágrafo único só permite reduzir. Aceita a punição apenas em **danos em massa com culpa grave** (item 13.2).

16.4 Antônio dos Reis Júnior: função promocional

Doutor pela UERJ; diretor-adjunto do IBERC. Sistematizou a função na tese de doutorado.

Em uma frase

O direito pode **premiar** quem repara o dano espontaneamente, em vez de só castigar. Reis a chama de a "mais neófita" das funções.

- **Origem:** a discussão tem cerca de uma década; Rosenvald fez um dos primeiros tratamentos técnicos. Reis lhe deu sistematicidade e conteúdo próprio, para que fosse **autônoma**.

- **Base teórica: Norberto Bobbio.** A **sanção negativa** reage ao ilícito (mal por mal) e serve às condutas que devem ser obrigatórias. A **sanção positiva** premia condutas importantes, mas não exigíveis: o Estado não obriga ninguém a ser "pessoa ótima", mas pode incentivar. Até Kelsen admite uma função promocional genérica, ainda que "rarefeita".
- **Definição:** função que estimula a **reparação espontânea** do dano, em sentido amplo: aceitar o pedido da vítima, fazer acordo ou reparar em espécie (serviço, produto, atividade). O personagem é o "**bom sujeito**", que normalmente previne danos, mas numa sociedade de risco pode causá-los. A vítima que colabora também é "premiada".
- **Diferença para as outras:** a reparatória busca a reparação integral (nem mais, nem menos); a promocional busca **satisfazer o interesse da vítima**, que pode não coincidir com a reparação integral.

Vantagens para a vítima	*Vantagens para quem causou o dano*
Rapidez; economia de honorários, custas e provas técnicas; fim da incerteza ("sepultamento da incerteza"); reparação em espécie; menor custo emocional.	Menos incerteza e despesas; o pagamento prova fato extintivo se houver processo (e abate a condenação, mesmo que o acordo seja anulado); ganho de imagem; prêmios previstos em lei.

- **Onde já há sanção positiva:** redução dos honorários pela metade no pagamento espontâneo na execução (art. 827, §1º, do CPC), "claramente um prêmio"; agências reguladoras que consideram a reparação espontânea ao aplicar multas.
- **Limites que ele reconhece:** previsões dispersas, sem sistematização; cuidado com vulneráveis, para que o acordo não seja imposto a quem está em posição frágil.

> ***O caso da moderadora***
>
> Uma pessoa transexual ofendida numa pastelaria aceitou, em vez de indenização, dar uma **aula de cidadania** aos funcionários; o gerente fretou um ônibus e levou a equipe ao fórum. O interesse da vítima era reconhecimento e educação, e não dinheiro.

Contraste com Léo Vieira

Léo **discorda** da promocional como função atual: não há nada concreto, é ideia que pode frutificar, mas é questão de **lei a ser feita**, e nem o projeto de 2025 a incorporou. Anotação de aula: é a função **menos impactante** (item 13.3).

16.5 Nelson Rosenvald: função restitutória

Presidente do IBERC; autor de *A responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo*.

Em uma frase

Quem lucra com o ilícito devolve o lucro: a resposta do direito deve se medir pelo **ganho do ofensor**, e não só pelo dano da vítima.

- **Três palavras em inglês:** *liability* (indenizar, a visão clássica), *responsibility* (responsabilidade moral, ligada às funções punitiva e promocional) e *accountability* (prestar contas, ligada à prevenção). Ter uma palavra só em português nos prende à monofuncionalidade. Rejeita a ideia de que prevenir e punir seriam "efeitos colaterais" da compensação.
- **O ilícito lucrativo:** os agentes econômicos fazem a conta; se o lucro supera a indenização, o ilícito compensa. Princípio inglês: *tort must not pay*. Exemplos: uso da imagem alheia; patentes, direitos autorais e dados; 20 centavos cobrados a mais em milhões de contas; empresa que segue lucrando após desastre ambiental.
- **Virada:** de *loss-based* (mede pelo dano) para *gain-based* (mede pelo ganho).

Remédio	O que é	Exemplo
Disgorgement	Remoção dos lucros ilícitos; o teto é o benefício indevido. Evita o "curto-circuito do contrato" (usar o bem alheio sem contratar porque a indenização sai mais barata que o preço). Explicação kantiana (Ripstein): quem pega 10 e os transforma em 50 devolve 50.	Franquia que usa a marca de restaurante famoso sem contrato: provar o dano é difícil; pedir o lucro do infrator é fácil.
Reasonable royalty	Valor de uso de mercado; uma "barganha hipotética". Serve quando o ofensor **não lucrou**, mas economizou o preço da licença. Não são lucros cessantes.	Uso de patente alheia sem ganho.

- **Diferença para os danos punitivos:** o disgorgement tem teto (o lucro) e quer remover o ganho; os punitivos sancionam condutas especialmente reprováveis (ex.: o motorista do racha que atropela) e podem superar qualquer lucro.
- **No Brasil:** o art. 210 da LPI reúne os três remédios (lucros cessantes, lucros do infrator e valor da licença).
- **Europa:** no DCFR e nas diretivas de propriedade intelectual (2004) e de segredos comerciais (2016), a vítima **escolhe** o remédio (*private enforcement*): deixa de ser agente passivo e vira reguladora do mercado.
- **Crítica ao STJ (caso Giovanna Antonelli):** o STJ concedeu o lucro ilícito, mas pelo caminho do **enriquecimento sem causa**, por partir da premissa de que responsabilidade civil só indeniza (art. 944). Com Peter Birks, Rosenvald distingue **fontes** das obrigações (contrato, ilícito e enriquecimento, este residual) de **remédios** (compensação, restituição, valor de uso), que servem a qualquer fonte. Restituição e enriquecimento "não são irmãos siameses".
- **Proposta final:** trocar "reparação integral" por **função reconstitutiva** (como no Código Civil português): reconstituir o equilíbrio entre as partes, seja reparando a vítima, seja devolvendo o ofensor à situação anterior ao ilícito (justiça corretiva de Aristóteles).

- **Dá para cumular?** Para Rosenvald, **não**: compensação, disgorgement e valor de uso são caminhos **alternativos**. Há quem admita cumulação; o ponto é controvertido.

> ***Correção de data***
>
> O material da palestra fala em diretiva de segredo comercial de 2017; a **Diretiva (UE) 2016/943** é de 2016 (transposição até 2018). A de propriedade intelectual é a 2004/48/CE.

> ***Contraste com Léo Vieira***
>
> Léo vê a restitutória como função **disruptiva** e critica o **nome**: "restituir" remete a reparar. Reconhece, porém, que a expressão se consagrou pelo uso (item 13.4). A convergência com a aula: os caminhos são **excludentes** entre si, exatamente como diz Rosenvald.

16.6 Visão de conjunto e confronto com a aula

Função	Palestrante	Pergunta central	Léo Vieira
Preventiva	Thaís	Como evitar o dano? (tutela inibitória material)	Valoriza a reflexa; contra responsabilidade sem dano.
Punitiva	Fernanda	Como desestimular a conduta grave? (pena privada)	Contra (art. 944), salvo danos em massa com culpa grave.
Promocional	Reis	Como estimular a reparação espontânea? (prêmio)	Discorda; lei a ser feita; a menos impactante.
Restitutória	Rosenvald	Como impedir que o ilícito compense? (disgorgement, royalty)	Disruptiva; nome inadequado.

Pontos de convergência dos palestrantes: "direito de danos" é rótulo reducionista; é preciso olhar a conduta do agente e o equilíbrio entre as partes; a vítima deve ter mais autonomia para escolher o remédio (desculpas, retratação, reparação não pecuniária); enquanto o ilícito compensar, continuará; mediação e autocomposição ganham espaço.

Observação da moderadora: os juízes já punem de modo implícito, majorando indenizações contra grandes litigantes sem dizer que estão punindo. A decisão "não pode ser uma caixinha de surpresa": é preciso transparência sobre por que o valor foi majorado.

> ***Como usar em prova***
>
> A palestra apresenta o lado **favorável** à multifuncionalidade. Em resposta discursiva, exponha a posição do palestrante ("segundo Rosenvald...") e, em seguida, a crítica de **Léo Vieira** (art. 944, princípio da legalidade das penas, ausência de lei). O art. 944 continua em vigor.

17. Quadro-resumo: posições de Léo Vieira

Tema	Posição dominante ou legal	Léo Vieira
Dano estético	Autônomo (Súmula 387 STJ).	Não é terceira categoria: é dano moral e/ou material (livro).
Natureza do nexo	Naturalística (Cavalieri, Diniz).	**Jurídica** (livro, com Sanseverino).
Art. 403 do CC	Invocado pela direta e imediata.	Só trata de inexecução contratual; o Código **não adotou nenhuma** teoria.
Teorias do nexo	Sem hegemonia; STJ com certo predomínio da adequada; art. 403 invocado pela direta e imediata.	**Causalidade adequada.** Abertura é compatível com um CC de cláusulas gerais.
Perda de uma chance	Dano autônomo.	**Flexibilização do nexo** ("nexo presumido"); usar com parcimônia, só com culpa elevada.
Excludentes	Muitos as confundem.	Exercício regular de direito exclui a responsabilidade sem excluir o nexo; estado de necessidade não exclui a responsabilidade.
Culpa levíssima	Brocardo romano: basta.	**Não basta**; art. 944, p. único, vale também na objetiva.
Crânio frágil	Responde pelo resultado mais grave.	Crítica de Schreiber: só com conhecimento ou previsibilidade.
Fato exclusivo da vítima	Também chamado "culpa exclusiva".	**"Fato"**, por causa dos inimputáveis.
Fortuito x força maior	Alguns autores distinguem.	**Mesma coisa**; importa a inevitabilidade.
Cirurgia estética	Obrigação de resultado (STJ).	**Obrigação de meio** (pele, efeitos randômicos; saúde psíquica); anestesia e transfusão também.
Medicina e art. 927, p. único	Há quem veja atividade de risco.	Medicina lida com **perigo**, não com risco; responsabilidade subjetiva.
Iatrogenia	Exercício de direito ou força maior, para alguns.	Excludente típica, de difícil enquadramento.
Falta de consentimento	Timbó: novo dano, indenização menor.	**Responsabilidade objetiva "agravada"**, prejuízo total, mesmo em complicação estatisticamente prevista.

Causalidade alternativa	Grupo responde solidariamente.	Teoria "bem interessante", mas exige **conexão fática** e presença física (torcida, caso Kevin Espada).
Prescrição (médico)	STJ: 5 anos (CDC); tendência de 10 para o consumidor.	Pensa diferente (anotação); coerente com sua tese, aplicaria o regime do CC.
Prova do consentimento	Termo escrito (TCLE).	**Videogravação** pelo próprio médico, autorizada e arquivada no prontuário; nenhuma norma a proíbe; gravação clandestina é lícita, mas fere a boa-fé (e-book, 2020).
Paciente recusa a filmagem	Meneses (CREMEB): o médico não deve deixar de atender.	Fora de urgência, o médico pode **recusar e encaminhar** (art. 36, §1º, CEM), sem abuso de direito.
CDC na relação médico-paciente	Aplica-se (STJ).	**Não se aplica** (analogia com a advocacia).
Hospitais	Três correntes (Benjamin, Kfouri/ Stoco, Cavalieri).	Adere a **Stoco/Kfouri**: exige culpa do médico; hospedagem é objetiva; médico estranho não gera responsabilidade do hospital.
Função preventiva	Rosenvald: inclusive sem dano.	Valoriza a reflexa; **contra responsabilidade sem dano**.
Função punitiva	Defendida por C. Lima Marques e F. Ivo.	**Contra** (art. 944), salvo danos em massa com culpa grave.
Função promocional	Rosenvald; sistematizada por Antônio dos Reis Júnior.	**Discorda**; lei a ser feita. A menos impactante das funções.
Função restitutória	Rosenvald; art. 210 LPI.	Disruptiva; nome inadequado.
Subteorias do risco	Risco criado no art. 927, p. único.	Tema anunciado para aprofundamento.
Responsabilidade proativa	Apresentada como terceiro gênero.	**Não é terceiro gênero**: dever jurídico autônomo e complementar (sanção da ANPD); aproxima-se da subjetiva. **Cai na prova.**
LGPD	Divergência objetiva x subjetiva x proativa; slide da aula: culpa presumida relativa.	**Subjetiva** fora do consumo; controlador responde pelo operador (art. 932, III).

18. Referências

Doutrina citada em aula

- **SANTOS, Leonardo Vieira. *Responsabilidade civil médico-hospitalar e a questão da culpa no direito brasileiro*. Salvador: JusPodivm, 2008.** (livro do professor)
- **SANTOS, Leonardo Vieira. Da (im)possibilidade de videogravação do consentimento esclarecido pelo médico nos contratos de tratamento. In: HIRSCH, Fábio Periandro de Almeida (coord.); ANDRADE, Rodrigo (org.). *Vida e legado jurídico de Antônio José Marques Neto: estudo de admiradores em homenagem à sua memória*. Salvador: Direito Levado a Sério, 2020, p. 265-280. ISBN 978-65-87020-16-7.** (artigo do professor)
- NILO, Alessandro Timbó. *O contrato de tratamento no direito brasileiro*. Curitiba: Juruá, 2020.
- IDP; IBERC. *As funções da responsabilidade civil*. Webinar do Grupo de Pesquisa "O Direito Privado no Século 21", 2020. Palestrantes: Thaís Pasqualotto, Fernanda Ivo Pires, Antônio dos Reis Júnior e Nelson Rosenvald.
- PIRES, Fernanda Ivo. *Responsabilidade civil e o efeito punitivo da reparação*. 2014.
- VENTURI, Thaís G. Pascoaloto. *Responsabilidade civil preventiva: a proteção contra a violação dos direitos e a tutela inibitória material*. São Paulo: Malheiros, 2014.
- ROSENVALD, Nelson. *A responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo*. Salvador: JusPodivm, 2019.
- CALABRESI, Guido; MELAMED, A. Douglas. Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral. *Harvard Law Review*, v. 85, n. 6, p. 1089-1128, 1972.
- BOBBIO, Norberto. *Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito*. Barueri: Manole, 2007.
- ALVIM, Agostinho. *Da inexecução das obrigações e suas consequências*. São Paulo: Saraiva.
- AGUIAR DIAS, José de. *Da responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Forense.
- BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. *Manual de direito do consumidor*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- CAVALIERI FILHO, Sergio. *Programa de responsabilidade civil*. São Paulo: Atlas.
- FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. *Curso de direito civil: responsabilidade civil* e *Novo tratado de responsabilidade civil*.
- GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Novo curso de direito civil*, v. 3: Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito civil brasileiro*, v. 4: Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva.
- KFOURI NETO, Miguel. *Responsabilidade civil do médico*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- NORONHA, Fernando. *Direito das obrigações*. São Paulo: Saraiva. (leitura recomendada para nexo causal)
- ROSENVALD, Nelson. *As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil*. São Paulo: Saraiva.
- SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. São Paulo: Atlas.
- STOCO, Rui. *Tratado de responsabilidade civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- NILO, Alessandro Timbó. A natureza jurídica da relação paciente-médico e a (in)aplicabilidade do CDC na resolução das demandas cíveis. Artigo científico.
- RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Nexo causal probabilístico: elementos para a crítica de um conceito. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, v. 8, p. 115-137, jul./set. 2016.
- DORTAS, Raquel. Responsabilidade civil na LGPD. Slides de aula, 29 out. 2026.

- CAPANEMA, Walter Aranha. A responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados. *Cadernos Jurídicos*, São Paulo, ano 21, n. 53, p. 163-170, jan./mar. 2020.
- AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. *Guia orientativo para definições dos agentes de tratamento de dados pessoais e do encarregado*. Versão 2.0. Brasília: ANPD, abr. 2022.
- Pesquisa de jurimetria "Responsabilidade civil e LGPD", material de aula.
- PAMPLONA FILHO, Rodolfo; ANDRADE, Luiz Carlos Vilas Boas. A torre de Babel das novas adjetivações do dano.
- MAGADAN, Gabriel. As teorias da causalidade e suas aplicações nos tribunais brasileiros. *Migalhas de Responsabilidade Civil*, 9 abr. 2024.
- CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexo causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
- SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. *Responsabilidade civil no Código do Consumidor e a defesa do fornecedor*. São Paulo: Saraiva.
- Também citados em aula, sem obra indicada nas anotações: Thiago Borges (função punitiva), Fernanda Ivo, Ruy Rosado de Aguiar, René Demogue e Nelson Hungria.

Legislação

- Código Civil (Lei 10.406/2002): arts. 928, 932 a 938 (responsabilidade indireta), 948 a 950; arts. 186, 188, 205, 206, 392, 393, 399, 403, 735, 927, 928, 929, 930, 932, 938, 942, 944, 945 e 951.
- Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990): arts. 6º, VIII; 14; 27; 40.
- Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015): arts. 373, §§1º e 2º; 384 (ata notarial).
- Código Penal: art. 13. Constituição Federal: art. 21, XXIII, "d".
- Decreto 2.681/1912 (estradas de ferro); Lei 9.279/1996 (Propriedade Industrial), art. 210; Lei 12.737/2012 (Carolina Dieckmann); Lei 12.842/2013 (Ato Médico); Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 19 e 21; Lei 13.709/2018 (LGPD), arts. 2º a 6º, 8º, 18, 37 a 48 e 52. EC 115/2022 (art. 5º, LXXIX, CF).
- Código de Ética Médica (Resolução CFM 2.217/2018): Princípios IX e XX; arts. 22 e 34. Código de Nuremberg (1947); Declaração de Helsinque (1964).
- Lei 12.842/2013 (Ato Médico), art. 2º. BGB alemão, §§ 630a a 630h (contrato de tratamento).
- CF, art. 5º, X e XII; CC, arts. 11, 15, 20, 187, 189, 422; CP, art. 154; CEM, arts. 22, 24, 36, §1º, 89, §2º, e Cap. II, IX; Res. CFM 2.145/2016 (CPEP); Enunciados 4, 139 e 404 do CJF; Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos (UNESCO, 2005), arts. 6º e 9º; Lei 13.989/2020 (revogada pela Lei 14.510/2022); Res. CREMEB 367/2020.
- Pareceres: CFM 03/1999, 03/2011, 47/2015, 05/2016; CREMEB 12/2009, 07/2012, 16/2015; CRM-PR 2.609/2017; CRM-SE 01/2018; CRM-MT 39/2019; CRM-MG 126/2019.
- CDC, arts. 12, §3º; 14, §3º; 38 (ônus *ope legis*). MP 966/2020; LINDB, art. 28.

Jurisprudência

- STF, RE 130.764/PR, rel. Min. Moreira Alves, 1992 (dano direto e imediato).
- STF, RE 608.880/MT, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 8/9/2020, Tema 362 (foragido; nexo causal direto).
- STJ, REsp 466.730/TO, 4ª Turma, j. 23/9/2008 (CDC afastado em cirurgia de catarata).
- STJ, REsp 532.377, 539.077, 757.867, 914.105 e 1.134.889 (CDC não se aplica a advogado e cliente).
- Enunciado 191 da III Jornada de Direito Civil do CJF (hospital responde pelos atos culposos dos médicos do corpo clínico).

- STF, Temas 952 e 1.069 (RE 979.742 e RE 1.212.272), j. 25/9/2024 (recusa de transfusão por Testemunhas de Jeová).
- STF, Temas 987 e 533 (RE 1.037.396 e RE 1.057.258), j. 26/6/2025 (art. 19 do Marco Civil).
- STF, Súmula 187. STJ, Súmula 479.
- STJ, REsp 788.459/BA, 2005 (Show do Milhão, perda de uma chance).
- STJ, REsp 1.374.284/MG, repetitivo (dano ambiental, risco integral).
- STJ, REsp 1.180.815/MG (cirurgia estética, obrigação de resultado).
- STJ, EREsp 1.280.825/RJ, 2ª Seção, rel. Min. Nancy Andrighi, 2018, e EREsp 1.281.594/SP, Corte Especial, 2019 (prescrição contratual de 10 anos).
- STF, gravação por interlocutor (rel. Min. Ellen Gracie, RT 826/524); STJ, REsp 1.113.734/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 28/9/2010.
- STF, ADIs contra a MP 966/2020 (rel. Min. Roberto Barroso, 2020): erro grosseiro e princípios da precaução e da prevenção.
- STJ, AREsp 2.130.619/SP, 2ª Turma, j. 7/3/2023 (vazamento de dados).
- STJ, REsp 2.121.904/SP, 2.133.261/SP, 2.115.461/SP, 2.206.924/SP, 2.077.278/SP, 2.187.854/SP; AgInt no AREsp 2.170.495/SP; Tema 1.404 (ProAfR no REsp 2.226.097/SP) (LGPD).
- STJ, REsp 844.736/DF, 2009 (spam).
- STJ, REsp 1.152.541/RS, 2011 (método bifásico). Súmulas 227 e 387 do STJ.

Fontes consultadas na internet

- Caso Kevin Espada (Oruro, 2013): Jornal do Brasil, "Corintianos desembarcam em SP após quase quatro meses presos na Bolívia", 9/6/2013 (jb.com.br); "Gaviões da Fiel entregará menor responsável por disparo de sinalizador", 24/2/2013.
- Dizer o Direito: "O vazamento de dados pessoais não gera dano moral presumido" (2023). dizerodireito.com.br/2023/03/o-vazamento-de-dados-pessoais-nao-gera.html
- Machado Meyer: "STF muda regime de responsabilização das plataformas". machadomeyer.com.br
- Damásio Jurisprudência: Tema 1.069 do STF. juris.damasio.com.br/temas/stf/1069

Caderno de estudo pessoal. Posições de Léo Vieira registradas a partir das anotações de aula. Os quadros laranja indicam correções ou atualizações a partir da legislação e da jurisprudência; vale confirmar com o professor como ele espera que sejam tratadas em prova.